

De esos dos aspectos se originan dos posturas o criterios.

De acuerdo con el primero —denominado voluntarista—, si la declaración es susceptible —dada la obscuridad de la misma— de dos o más sentidos, el intérprete debe escrutar hasta donde le sea posible la voluntad interna del declarante. De acuerdo con el segundo —denominado declaracionista— hay que atenerse únicamente a la voluntad declarada, interpretándola de manera aislada de las motivaciones internas del declarante.

Este último criterio responde a una línea de interpretación objetiva, que se concilia con la idea de la justicia. En cambio, el primero se corresponde con una interpretación subjetivista, tratando de satisfacer la idea de la equidad.

II. Respecto de este problema, podemos señalar la siguiente evolución en el Derecho Romano.

(A) En el viejo *ius civile*, en el cual los negocios celebrados eran muy solemnes, no se conoció otro método interpretativo que el "objetivo". De este modo, si alguien había celebrado un *nexum*, por ejemplo, quedaba obligado por la sola exteriorización del acto. Se puede, pues, muy bien decir que el efecto del negocio es consecuencia de la forma del acto y no de la voluntad.

(B) Pero luego, a medida que se van admitiendo los actos y negocios jurídicos del *ius gentium*, todos ellos informales, se va a ir abriendo lentamente el camino para considerar la voluntad que impulsó al declarante a la realización del acto o negocio. La perspectiva así abierta tenía grandes posibilidades dado que el pretor —por tratarse la mayoría de los casos de actos o negocios celebrados a la luz de la *bona fides**— tenía una gran libertad de apreciación. Nos encontramos acá con que la voluntad deja de ser prisionera de la forma.

* El caso más célebre y ejemplificador estuvo representado por la famosa *Causa Curiana*. Ocurrió que una persona hizo su testamento, y esperando que su mujer le diera a luz un hijo, lo instituyó heredero, previendo que pudiera nacer después de su muerte —hijo póstumo—. A su vez estableció una cláusula que se conoce como sustitución pupilar*, que

fijaba que en los casos en que el hijo instituido heredero falleciera antes de alcanzar la pubertad, el heredero pasara a ser M. Curio. *Una vez muerto el testador, el hijo esperado no nació: la madre en realidad no había quedado embarazada. Entonces se planteó una controversia entre Coponio, que era un heredero ab intestato** —defendido por Q. M. Scævola— y M. Curio, el heredero sustituto —defendido por L. Licinio Craso—. El alegato del primero —ejemplo típico de interpretación declaracionista u objetiva— se basó en que no habiendo nacido el heredero instituido, en realidad no había heredero y por ello caía el testamento. En cambio, el argumento del segundo —ejemplo de interpretación voluntarista o subjetiva— se basó en que la voluntad del testador estaba expresada por la adición de la sustitución pupilar, demostrativa del interés que tenía en que la herencia no pasara a sus agnados.

La causa tuvo mucha importancia, por cuanto fue juzgada ante el tribunal de los centumviro, que había sido tradicionalmente apegado a la interpretación por las formas, pero que en este caso se inclinó por Curio, interpretando la voluntad del causante.

(C) No debemos por ello creer que los romanos se guiaron a partir de entonces por una interpretación subjetivista a ultranza y trataron de indagar los más íntimos recovecos internos de la voluntad. Partían en principio de lo expresado —*verba*— tratando de conciliar la interpretación con lo querido —*voluntas*—. De este modo, no sólo los actos informales del *ius gentium*, sino también los que requerían solemnidades, fueron también inquiridos en su aspecto subjetivo.

* Véase este ejemplo del jurista Pomponio. "Si yo hubiera estipulado lo siguiente: «Prometes que me darás 10 ó 5?», se deben los 5; o «Prometes que me lo darás en las calendas de enero o de febrero?», es lo mismo que si yo hubiera estipulado para las calendas de febrero". En este negocio formal —*stipulatio*— se ha interpretado inquiriendo la *voluntas* del contratante, que al permitir lo menos en dinero y la permisión de lo más en tiempo, está subjetivamente autorizando al otro estipulante a gozar de esa permisión.

(D) Finalmente, en la época posclásica, sobre todo en las escuelas orientales, la interpretación se va a inclinar por la posición voluntarista, en mucho influida por la doctrina de la voluntad expresada en las corrientes helénicas y en los estudios teológicos cristianos. Incluso en algunos negocios, como el testamento y la estipulación, la *voluntas* toma decidida prevalencia sobre los *verba*. Contribuyó también a esto el decaimiento de las formas solemnes para estos negocios.

DIVERGENCIA ENTRE VOLUNTAD Y DECLARACION

I. La divergencia entre lo declarado y lo realmente querido puede dar lugar a la simulación. Las partes pueden querer aparentar la realización de un negocio en forma lícita, pero con vistas a defraudar a la ley, como cuando las partes simulan una compraventa para contravenir las limitaciones que rigen para las donaciones. * Otro caso muy común es el que daba lugar a la acción Pauliana. * Este último caso es llamado de simulación "absoluta" — se ha "declarado" un negocio, pero en realidad no se ha "querido" hacer ninguno— y para el derecho es nulo. En cambio, el primero de los ejemplos es llamado de simulación "relativa" —se ha "declarado" un negocio, pero en realidad se ha "querido" hacer otro distinto—. En estos casos el negocio simulado puede tener validez siempre que se constituya en virtud de una causa lícita.

II. Otro caso de divergencia entre la voluntad y la declaración puede darse en el supuesto de la reserva mental que ocurre cuando una de las partes guarda para su fuero interno un determinado sentido de lo que exteriormente se ha "declarado" pero que no ha sido efectivamente expresado. La reserva mental no fue tenida en cuenta en el Derecho Romano, adquiriendo importancia recién en el medievo a propósito de la interpretación del consentimiento del matrimonio realizado por el derecho canónico.

III. Finalmente, los negocios hechos por diversión o broma —*iocandi causa*— carecen de seriedad y por lo tanto son obviamente ineficaces.

INEFICACIA DEL NEGOCIO JURIDICO

I. Los juristas romanos, sin llegar a estructurar una teoría de la ineficacia de los actos y negocios jurídicos, establecieron, siguiendo los casos concretos, una serie de reglas que van a ser

precursoras de las construcciones logradas por el derecho posterior.

Debemos distinguir dos supuestos: (A) el caso de la nulidad, en el cual el acto o negocio sólo tiene una mera apariencia de ser, pero en realidad carece de alguno de los elementos esenciales, razón por la cual se lo considera inexistente o totalmente inválido; (B) el caso de la anulabilidad, en el cual el acto o negocio existe y en principio produce los efectos jurídicos que se propusieron las partes; pero éstas pueden pedir su anulación, o decretarla el juez debido a un obstáculo jurídico existente y atendible.

- En el derecho antiguo, los actos y negocios del *ius civile* son susceptibles de nulidad y no de anulabilidad. Se debe ello a su carácter solemne: en principio tienen vigencia, salvo que no se hayan realizado las formas respectivas o que las personas que los ejecuten sean manifiestamente incapaces —por ejemplo un *impuber* o un *pupus* sin la *auctoritas* * de su tutor—; o respecto de un objeto prohibido, ilícito o imposible. La terminología usada se refiere a ese negocio como *nullus in nullius momenti* (nulo en todo instante), o meramente *nullum o inutile*. Para el derecho, ese acto o negocio nunca ha podido producir efectos.
- En cambio, los actos y negocios del *ius gentium* o del *ius honorarium*, si bien son susceptibles de nulidad por carencia de algún elemento esencial, también pueden ser anulados cuando el pretor, considerando la realidad integral del negocio en sus aspectos objetivo y subjetivo a la luz de la equidad, entiende que presentan un obstáculo atendible para que se lo torne ineficaz para el futuro.
- Esta situación fue evolucionando en el derecho clásico, de tal modo que incluso los negocios formales del *ius civile*, que reúnen los elementos esenciales, van a poder ser interpretados por el pretor, el cual, cuando lo consideraba oportuno (por ejemplo, si existía un vicio de la voluntad) podía otorgar a la parte una *exceptio* para detener los efectos de la acción incoada o incluso denegar directamente la acción (*non dare actionem*). También podía otorgar una medida extraordinaria, como por ejemplo la *in integrum restitutio* * en favor de un menor de 25 años.
- Más tarde, en el derecho posclásico, superadas las diferenciaciones entre el *ius civile* y el *ius gentium* en estos aspectos, el criterio se unificará en cuanto a los actos ineficaces, admitiéndose la anulación o la anulabilidad de los mismos.

VICIOS DE LA VOLUNTAD

II. En las causas de anulabilidad nos encontramos con los supuestos de vicios de la voluntad. La doctrina romana nos presenta tres casos: (A) el error; (B) el dolo y (C) la violencia.

(A) EL ERROR

Se entiende por error el falso conocimiento que la o las partes tienen sobre el acto o negocio llevado a cabo o sobre un aspecto esencial del mismo.

El error a que nos referimos es el error de hecho (*error facti*). Existe el error de derecho (*error iuris*), que versa sobre la ignorancia o ausencia total de conocimiento de las reglas jurídicas objetivas o sobre el conocimiento equivocado de las mismas. Por una mera razón de seguridad jurídica el error de derecho es inexcusable. Sin embargo, el Derecho Romano admitió que pudiera ser invocado por ciertas personas: los menores de 25 años, las mujeres, los soldados, los rústicos, etcétera.

El error puede versar ya sobre el negocio mismo, ya sobre distintos aspectos de él.

1) ERROR IN NEGOTIO

Tiene lugar cuando existe un desencuentro total entre lo que las partes han querido celebrar y lo realmente manifestado. Ello es lo que ocurre si Ticio cree haber dado una cosa a Sempronio en virtud de una compraventa, y Sempronio cree haberla recibido en virtud de una donación. Acá, directamente, no hay negocio, de tal modo que ni hay compraventa ni hay donación.

- * En el ejemplo, debido al disenso existente, resulta claro que el error es esencial. En los demás supuestos que analizamos a continuación, este requisito deberá ser tenido especialmente en cuenta, ya que los simples errores en las motivaciones resultan jurídicamente intrascendentes. Podemos, pues, decir que para que pueda causar la anulación del acto o negocio, el error deberá versar sobre aspectos esenciales de una persona o de una cosa.

- * Por otra parte, el error debe ser excusable, es decir, debe haberse producido no obstante la normal diligencia que toda persona pone en la atención de sus asuntos. De no ser así, el error se habrá producido por torpeza de la parte y en consecuencia no es atendible.

2) ERROR IN PERSONA

Tiene lugar cuando se ha realizado el negocio con una persona distinta de aquella con la cual se quería celebrar el mismo. Para ser esencial, la consideración de la persona tiene que haberse tenido especialmente en vista. Así, por ejemplo, cuando celebré un muto con Ticio, creyendo que era Sempronio, del cual conocía su solvencia económica y demás circunstancias personales.

- * Se distingue el error sobre el nombre de los errores sobre la identidad y sobre las cualidades. En el primero, el negocio será válido, por cuanto la sola equivocación sobre el nombre no resulta esencial para el negocio. En cambio, en los otros dos, el error puede acarrear la nulidad.
- * Los negocios sobre los cuales recae el error de identidad y de cualidades que pueden provocar la anulación de los mismos se los llama *in titutu personae*. Son, por ejemplo, la locación de obra, la sociedad, la donación, etcétera; es decir, aquellos que se han realizado teniendo como presupuesto esencial que la parte beneficiada o la otra parte es esa determinada persona y no otra. Fuera de este supuesto, el error será intrascendente.

3) ERROR IN CORPORE

Tiene lugar cuando he realizado el negocio sobre un objeto distinto del que creía celebrarlo. Así, creo haber comprado el campo A y resulta que se me ha vendido el campo B.

- * Aclaremos aquí, también, que el mero error sobre el nombre del objeto negocial no es esencial, como cuando compro un esclavo creyendo que se llama Sticho, pero en realidad se llama Pánfilo.

4) ERROR IN SUBSTANTIA

Tiene lugar cuando recae sobre las características esenciales del objeto del negocio. Así, por ejemplo, creo comprar una botella de vino y en realidad contiene vinagre. Creo comprar una fuente de oro, y es de bronce.

- * En estos supuestos, el error no es sobre el *corpus* del objeto —es decir, quise comprar esa botella y esa fuente—, sino sobre la *substantia rei*:

creía que era de vino y es de vinagre; creía que era de oro y es de bronce. El problema fue complicado en la doctrina romana. Así, en el caso del vicio, Juliano lo considera nulo, Marcelo se inclina por la negativa respecto de la anulación del negocio y Ulpiano, en cambio, por la afirmativa, si bien haciendo una distinción: si compraba vino y el vino luego se avinagraba, la compraventa era válida; en cambio, si se había dado vinagre por vino, era nula.

5) ERROR IN QUANTITATE

Tiene lugar cuando recae sobre la cuantía del objeto. Así, por ejemplo, si creo comprar diez caballos y en realidad la otra parte me ha vendido solamente cinco.

- En la doctrina clásica, los casos están tomados generalmente del error sobre la cantidad en la *stipulatio*, decidiéndose que al no haber coincidencia entre la pregunta —“¿Me prometes dar diez?”— y la respuesta —“Te prometo dar cinco”— no había consentimiento en el negocio. En cambio Justiniano, por razones de equidad y trayendo la experiencia de los contratos del *ius gentium*, decidió que el contrato era válido por la cantidad inferior. Así, en el ejemplo dado más arriba, se entendía que había consentimiento por cinco caballos.

(B) EL DOLO

Se entiende por dolo la realización de todo tipo de maniobra engañosa o maquinación astuta tendiente a provocar un estado de error en la otra parte con la cual realizamos el negocio. Se trata, pues, acá, no de un error involuntario, sino de un error provocado.

Los romanos distinguen entre el dolo bueno (normales artificios utilizados en los negocios) y el dolo malo, cuya definición es la que dimos arriba.

- En un comienzo el *ius civile* no admitió esta causal de ineficacia, razón por la cual los actos celebrados con dolo eran válidos.
- Pero luego, en tiempos de Cicerón, el pretor Aquilio Galo creó la fórmula de una acción penal, la *actio doli*, por la cual quien por engaño o fraude resultó perjudicado podía pedir el importe del daño sufrido. Esta acción tenía carácter infamante —por ello sólo se podía iniciarla en ausencia de otra—; además, se debía ejercitar dentro del año y contra el autor del dolo, siendo personal en el sentido de que no se transmitía a los herederos.
- Se admitió también una *exceptio doli*, otorgada a aquellos que eran de-

mandados por la realización de un acto doloso, y servía para evitar el progreso de la acción.

- Más adelante se va a admitir también una *in integrum restitutio*, por medio de la cual se deshacía el negocio, debiéndose devolver las prestaciones dadas.

Requisitos. — Para que se entienda que hay dolo se requieren los que se enumeran a continuación.

- 1) A diferencia de lo que ocurre en la violencia, el dolo debe provenir de la contraparte negociada y no de un tercero.
- 2) Las maniobras dolosas deben haber sido causa determinante de la realización del acto. En este caso se habla de dolo principal. En cambio, si el dolo es incidental, es decir cuando aun sin las maniobras dolosas el negocio lo mismo se habría celebrado, ello no puede causar la ineficacia del acto.
- 3) Debe ocasionar un daño importante.
- 4) No debe mediar dolo de ambas partes.

(C) LA VIOLENCIA

En este vicio de la voluntad debemos distinguir dos supuestos: (A) la violencia física (*vis absoluta*) y (B) la violencia moral o coacción (*vis coactiva*)

- El primer supuesto no interesa tanto para el análisis, ya que sólo se puede dar cuando alguien fuerce a otro a realizar un acto utilizándolo como mero instrumento. Aquí resulta evidente que falta la voluntariedad del acto, es decir, un elemento esencial para su realización.
- En cambio, el segundo dio motivo a una fórmula especial, debida al pretor Octavio —*fórmula Octaviana*, hacia el año 80 a.C.— De acuerdo con la dura fórmula del *ius civile*, el que realizaba un acto coaccionado no podía alegar dicho vicio —decía Paulo: “Quisiste constreñido, pero quisiste”—, pero a partir de la *fórmula Octaviana*, se pudo ejercitar la *actio quod metus causa*, por la que se pretendía la restitución de lo entregado por miedo, o, en su defecto, el cuádruplo de su valor —si se había podido ejercitar en el término de un año, pasado el cual sólo podía accionarse por el valor simple.
- A su vez, para poder repulsar una acción que se pretendía intentar en base a un acto realizado con violencia, se otorgaba la *exceptio quod metus causa*.

Requisitos. — Para poder alegar el *metus* o la *vis coactiva*, deben darse estas circunstancias: 1) debe haber una amenaza injusta, es decir, el preanuncio de querer hacer sufrir a otro un

mal. No es injusta la amenaza hecha al deudor de demandarlo ante la justicia. No interesa —a diferencia del dolo— si la amenaza proviene del que tiene interés en el negocio jurídico o de un tercero. 2) El mal con que se amenaza debe ser grave o inminente. 3) Debe estar dirigido a que la persona amenazada tenga que realizar el acto o negocio jurídico. 4) La amenaza debe ser seria, es decir, capaz de impresionar a una persona normal.

CAPITULO VIII

DEFENSA PROCESAL DE LOS
DERECHOS

I. Las normas jurídicas se distinguen de las otras por su carácter coactivo, en tanto el estado impone su cumplimiento, sanciona su violación y protege los derechos subjetivos que de ellas se deducen.

Precisamente, cuando los sujetos consideran que sus derechos no son respetados, recurren al estado en demanda de su reconocimiento y tutela.

Se llama proceso al conjunto orgánico y reglado de actos que deben desenvolverse ante los órganos específicos del estado —judiciales— para que éstos constaten la titularidad de los derechos subjetivos y la violación del derecho objetivo y, consecuentemente, impongan la reparación o sanción correspondiente.

II. Lo que posibilita el proceso es la acción, que, como afirmó Celso, no es sino el poder jurídico de perseguir en juicio lo que es debido.

• Actualmente, la acción se concibe sólo como un medio de defensa de derechos subjetivos preexistentes en el ordenamiento jurídico positivo, pero en el Derecho Romano el magistrado, en ejercicio de su función ju-

44

504 1

jurisdiccional, podía tanto otorgar acciones para tutelar situaciones de hecho no contempladas previamente por el *ius civile* como negarlas a titulares de derecho subjetivos derivados del derecho objetivo vigente. Las pretensiones o intereses jurídicos encontraban, pues, su efectiva tutela no en una necesaria condición de derechos subjetivos, sino en la concesión de una específica acción^o.

- La acción resultaba, así, no un inevitable corolario, un automático reflejo de la condición de derecho subjetivo, sino una cierta entidad en sí misma, independiente de la existencia previa de un derecho subjetivo y, a veces, por el contrario, engendradora indirecta de derechos: se tenía un derecho porque el magistrado prometía una acción para una determinada hipótesis.
- De allí que el estudio de las acciones fuera más bien tema del derecho material que del derecho adjetivo —procesal— y que se haya dicho que el Derecho Romano se presentaba como un sistema de acciones.

III. En general, se llama jurisdicción a la actividad de órganos del estado dirigida a formular y aplicar las concretas normas jurídicas que, de acuerdo con el derecho vigente, deben regular una determinada situación jurídica.

Pero en Roma la *iurisdictio* es desde el principio y por un largo tiempo considerada un poder o prerrogativa personal del magistrado que, aunque consiste en la enunciación de los principios jurídicos que encuadran o importan la controversia, no comprende la emisión de la sentencia: es decir, compete a la *iurisdictio* dar el planteo pero no la solución del caso.

Sólo a partir del siglo I de nuestra era comienza a estructurarse como una función del estado cumplida a través de funcionarios jueces, en el ámbito y medida —competencia— establecidos por el ordenamiento estatal.

Entonces la *iurisdictio* será más o menos asimilable a la de nuestros días, porque comprenderá también la facultad de emitir el *iudicium* o sentencia: habrá planteo y solución.

IV. Es que ha tenido lugar en el Derecho Romano una paulatina publicización del proceso, es decir, que al principio una moderada intervención del poder público en las controversias privadas fue incrementándose para resultar al final casi tan com-

pleta como en nuestros tiempos. Claro, la evolución en tal sentido no tiene por qué haber sido rectilínea: puede haber habido vacilaciones o regresiones, pero en sus grandes rasgos podríamos esquematizarla en tres etapas.

(A) Legitimación de la violencia de la defensa privada a través de modos de actuar con recaudos o condiciones controlados por una genérica opinión pública, es decir, sin intervención de órgano estatal específico: por ejemplo, el tratamiento del declarado *sacer*^{*} y la *pignoris capio*^{*}. Quedan amplios remanentes de esa modalidad en todos los períodos del Derecho Romano: fuera de casos taxativamente fijados por las leyes, la autodefensa no es reprimida, y sólo en la época de Justiniano —siglo VI d.C.— se impone que la defensa del derecho propio sólo pueda tramitarse a través de la administración pública de justicia.

(B) La intervención, a requerimiento de las partes, del estado 1) para controlar o disciplinar el accionar de la defensa privada, accionar que se irá estilizando o haciéndose simbólico, y 2) para llevar, con previo encuadre jurídico, o sin él, a la instauración de un arbitraje a realizarse, sea con procedimientos ordálicos, sea con análisis crítico de las pruebas aportadas.

(C) Actuación cada vez más insoslayable de la administración estatal con control total y exclusivo del proceso hasta la decisión del caso mediante la sentencia.

La etapa (A) es propia de los comienzos de Roma; la (B), en lo fundamental, corresponde al período republicano, aunque alcanza su apogeo técnico en el Principado, en el que ya a ir predominando la (C), que resulta exclusiva en el Imperio.

V. Durante la existencia de la comunidad romana los pleitos privados se tramitaron a través de tres sistemas procesales que se fueron sucediendo en el tiempo, pero con largos períodos de coexistencia. El sistema de las *legis actiones* —acciones de la ley— rige hasta el siglo II a.C., en que comienza a estructurarse el segundo sistema, el formulario. Luego aquél languidece, hasta

ser oficialmente abolido —salvo en algunas restrictas aplicaciones— por la *lex Iulia iudiciorum privatorum* del año 17 a.C. El sistema formulario se consagra, en coexistencia con el de las *legis actiones*, por la *lex Aebutia* (alrededor del 130 a.C.) y lo sustituye de acuerdo con la aludida *lex Iulia*. Estos dos sistemas tienen en común la división del proceso en dos etapas: la *in iure* (ante el tribunal), en la que el magistrado encuadra o plantea jurídicamente la controversia —*iurisdictio*— y establece la relación procesal, y la *apud iudicem* (ante el juez), en la que a un particular, designado específicamente para esa ocasión, le corresponde emitir la sentencia que resuelve el caso. A partir del comienzo de nuestra era, con el Principado se generaliza un sistema que, por haber unificado las dos etapas —la *in iure* y la *apud iudicem*— de los sistemas anteriores considerados variantes del *ordo iudiciorum privatorum* (orden propio de los juicios privados), fue llamado *extra ordinem* (fuera del orden normal) o extraordinario. Después de coexistir con el sistema formulario durante el Principado, será el sistema típico y exclusivo del Dominado.

EL SISTEMA DE LAS LEGIS ACTIONES

I. En la expresión *legis actiones*, la palabra *actio* significa modo de actuar y alude a los gestos y declaraciones rituales o solemnes, que, so pena de perder la instancia procesal, debían ser rigurosamente efectuados según prescribía la *lex*. De allí el nombre de acciones de la ley. También por considerar los romanos que ese sistema había sido introducido o, al menos, reglado por la ley por antonomasia, la de las XII tablas.

II. De las acciones de la ley, tres son declarativas, es decir, tienden a la elucidación de una controversia, y dos son ejecutivas, es decir, tendientes a una ejecución que sancione una relación jurídica no controvertible pero no cumplimentada, por ejemplo, una deuda declarada judicialmente pero no pagada todavía.

PROCEDIMIENTO

LAS PARTES

Sólo excepcionalmente era permitido participar en el proceso en lugar de otro: para hacer valer un derecho del pueblo romano contra un particular, para sostener el *status libertatis* * de una persona reivindicada como esclavo, para perseguir por hurto a quien había robado a un romano prisionero del enemigo o ausente por causa pública o a una persona sujeta a tutela. Por lo demás, el tutor sustituía a su pupilo infante * y el curador al *furiosus* * y tal vez al pródigo *.

IN IUS VOCATIO

Es la intimación verbal del actor a su contraparte para que ésta comparezca con él ante el tribunal. Ante la negativa manifiesta ante testigos podrá emplear la fuerza, que no podía legítimamente ser rechazada por el demandado, salvo por la intervención de un *vindex* que garantizara la oportuna presencia del demandado.

ETAPA IN IURE

I. Se llevaba a cabo ante el magistrado —¿el *rex* o los pontífices, en los tiempos más antiguos?—: el demandante debía recitar su reclamo necesariamente con las palabras sacramentales que figuraban en la ley o que le habían prescripto los pontífices o los jurisprudentes laicos consultados al efecto; el demandado, a su vez, respondía con palabras del mismo carácter.

El magistrado, por su parte, se limitaba a asegurar con su presencia el correcto accionar de las partes y a perfeccionar la instancia con su intervención.

II. Ahora bien, tratándose de acciones declarativas en las que se debía llegar a la elucidación de una controversia, si el derecho del actor no había sido cuestionado por el demandado,

45

504 1

el magistrado lo consagraba. Pero si había controversia, las partes llamaban a terceros como testigos de los términos de ella —*litis contestatio* (atestiguamiento de la disputa)— y obtenían del magistrado el nombramiento de un juez o un árbitro, que no tenía tal condición como permanente, pues era elegido de una lista de ciudadanos particulares —senadores en los primeros tiempos— y agotaría su nombramiento de juez en ese único litigio para el que era nombrado.

III. Con la *litis contestatio* quedaban definidos y fijados los extremos de la controversia, y el juez debía referirse siempre a la situación jurídica existente en ese momento.

LA ETAPA APUD IUDICEM

I. El lugar era el elegido por las partes, o los comicios o el foro. Allí se comenzaba con una sintética exposición del pleito, la que debía estar cumplida antes del mediodía. Si una de las partes no se había hecho presente hasta entonces, perdía la causa.

II. La faz *apud iudicem* no presentaba las rígidas formalidades de la anterior: el juez, recibida la producción de la prueba —casi siempre testimonios— y los alegatos de las partes, daba su sentir (*sententia* *) con la eventual ayuda de un *consilium* de asesores. Podía devolver el asunto al magistrado si no había llegado a verlo con claridad.

LA SENTENCIA

Impugnable e inapelable, no necesitaba ser motivada. Y una vez que resolvía la controversia, ésta no podía replantearse.

EJECUCION

Ante la falta de cumplimiento por la parte perdedora no quedaba otro recurso que otro proceso, el de la *legis actio per manus iniunctionem* *.

LEGIS ACTIO SACRAMENTO

Acción general, por ser adaptable a cualquier controversia para la que no se hubiera prescrito un diverso modo de actuar.

I. En la etapa *in iure*, cada una de las partes hacía la afirmación solemne y contrastante de sus derechos.

- En la *actio sacramento in rem*, alternativamente tocaban con una varita la cosa litigiosa o una parte representativa mientras decían más o menos así: "Digo que esta cosa es mía según el derecho de los quirites y conforme a la relación jurídica de la que es objeto. En lo que a ti respecta, como lo he afirmado, impongo mi reivindicación".
- En la *actio sacramento in personam* el actor habría comenzado diciendo: "Afirmo que corresponde que tú me des..." Se ignora si debía hacer mención de la causa. El demandado habría negado en términos simétricos.

II. Luego venía la provocación o desafío recíproco al *sacramentum*: cada parte comprometía bestias, en los primeros tiempos, o quinientos o cincuenta ases —según la importancia del pleito— para el caso de que su afirmación fuera perjurá.

III. El magistrado, luego de asignar provisionalmente a una de las partes la cosa litigiosa, nombraba, de entre ciudadanos privados, al juez ante el que debía iniciarse la etapa *apud iudicem*.

- En los primeros tiempos, caracterizados por la no discriminación entre lo jurídico y lo mágico-religioso, tal vez el mismo *rex* o los *pontífices* protagonizaron las dos etapas procesales, procediendo en la segunda con ritos ordálicos —tal vez la observación de las entrañas de las bestias entregadas— para que la divinidad indicara quién había perjurado...

IV. En tiempos posteriores, y al compás de la laicización del derecho, el juez debía recurrir a medios racionales de prueba para dar su sentencia de cuál *sacramentum* era *iustum* y cuál *iniustum*, lo que entrañaba decidir indirectamente sobre el contenido de la controversia.

LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRIVE POSTULATIONEM

Era la acción de la ley por el reclamo de un juez o un árbitro: introducida o admitida por la ley de las XII tablas, pres-

cindía de la apuesta y llevaba directamente al nombramiento de un juez privado para pronunciarse sobre la cuestión.

En los primeros tiempos debe de haberse utilizado sólo para controversias sobre divisiones o delimitaciones de bienes, pero la ley de las XII tablas la aplicó a pleitos sobre créditos originados en la *sponsio* *.

LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM

Nueva acción introducida, a mediados del siglo III a.C., por una *lex Silia* para el reclamo de sumas definidas de dinero —*certa pecunia*— y ampliada por una *lex Calpurnia* para el reclamo de cosa determinada —*certa res*.

Al igual que en la *legis actio per iudicis arbitrive postulationem*, había una directa —es decir sin el recurso a una apuesta— afirmación y correlativa denegación de una obligación y el pedido de un juicio.

- * Pero en la *per condictioem* la convocatoria —*condictio*— al juicio tenía un plazo fijo de treinta días y no había, en la instancia *in iure*, necesidad de dar las razones en las que se basaba la pretensión.
- * Tal vez se completaba con una *sponsio* de pagar el perdedor de la litis un tercio del monto de lo reclamado, como pena en favor del ganador.

PIGNORIS CAPIO

De las acciones ejecutivas, la *pignoris capio*, en realidad, no se lleva a cabo ante el magistrado: simplemente se trata de que, en ciertos casos marcados por el ordenamiento jurídico, es lícito, sin más, para el acreedor tomar en prenda una cosa del patrimonio del deudor.

MANUS INIECTIO

En cambio, hay un verdadero procedimiento ante el magistrado en el caso de la *manus iniectio* (echar mano a alguien): en virtud de sentencia en un juicio declarativo o por el carácter de la causa —*nexum*—, un particular tenía derecho, luego de ha-

ber llevado a su deudor ante el tribunal y de haber sido éste declarado *addictus* por el magistrado, a apoderarse de su deudor y retenerlo encadenado en su casa. Si no cumplía con lo debido antes de los sesenta días, debía ser llevado tres días consecutivos de mercado a la plaza pública frente al magistrado y su deuda anunciada públicamente, tanto para ver si alguien lo ayudaba como, tal vez, para que otros acreedores pudieran hacer valer sus créditos. No satisfecha la deuda transcurridos los sesenta días, el deudor podía ser vendido como esclavo fuera del territorio romano; o muerto, y su cuerpo repartido entre los acreedores, sin importar, como parece decir la ley de las XII tablas, que alguien retirara un pedazo mayor que el proporcionado a su crédito... En realidad, el texto del que se ha extraído esta cruenta disposición es muy controvertido y, por otra parte, no nos ha llegado ninguna referencia de un caso concreto en que se la hubiera aplicado.

- * Distintas leyes ampliaron las hipótesis que daban lugar a una *manus iniectio pro iudicato*, es decir, como si el deudor hubiese sido declarado tal en juicio.
- * La *manus iniectio* no podía ser rechazada ni discutida por el deudor sino por un *vindex* o garante, que arriesgaba pagar el doble de lo debido si perdía la instancia judicial.
- * Algunas leyes fueron introduciendo, para ciertos casos, un nuevo tipo de *manus iniectio*, llamada *pura*, por la que era posible al mismo deudor cuestionarla, siempre con el riesgo de pagar el doble.

EL PROCEDIMIENTO FORMULARIO

HISTORIA

I. Se vincula el origen del procedimiento formulario con la actividad jurisdiccional del pretor peregrino creado en el 242 a.C. para entender en asuntos con peregrinos y de éstos. Este pretor no necesitó ajustarse al rígido y formalista sistema de las *legis actiones*, al que no tenían acceso los no ciudadanos. Fue, por lo tanto, con toda libertad, desarrollando un tipo de proceso que, en lo general, seguía el esquema de arbitraje obligatorio de las *legis actiones*, con sus dos etapas: la *in iure*

46

504 1

y la *apud iudicem*. Claro que, con palabras o referencias de las *leges*, en lugar de las formulaciones solemnes, el pretor peregrino acostumbró a plasmar por escrito, previa información, consulta, discusión y asentimiento con las partes y de las partes, la impostación de la controversia en base a la norma correspondiente, deducida de la institución romana extendida a los peregrinos o —lo que era más frecuente— del principio de la *bona fides* *. De aquí la expresión de “actuar *per concepta verba*”, es decir, dar lugar al *iudicium* con palabras adaptadas en cada caso a la concreta controversia; ello, en contraposición con las *certa verba* (palabras determinadas), siempre las mismas, según la genérica acción que se ponía en juego con el procedimiento de las *legis actiones*. Se originó así la fórmula, * alma del nuevo procedimiento que de ella tomaría su nombre.

II. Cuando el pretor urbano fue incorporando en su *iurisdictio* las nuevas instituciones y criterios del *ius gentium*, consagrados en el tribunal del pretor peregrino, también fue imitando esas formas más libres, más funcionales, con que éste organizaba el proceso. En especial, empezó a utilizar la fórmula en ocasión de juicios basados no en el *ius civile* —en esos casos debía emplearse el rígido y formalista sistema de las *legis actiones*—, sino en el sometimiento a su *imperium* de controversias sobre instituciones procedentes del *ius gentium*, pero en las que eran partes ciudadanos romanos que voluntariamente aceptaban aquel procedimiento *per formulas*.

III. Alrededor del 130 a.C. la *lex Aebutia* autorizó al pretor urbano a utilizar ese procedimiento, a pedido de las partes, también en todas las controversias sobre instituciones del *ius civile*. Las *legis actiones* cayeron rápidamente en desuso y en el nuevo procedimiento halló el pretor un más adecuado instrumento para una actividad jurisdiccional más libre de las formas y contenidos del viejo *ius civile*.

IV. Hasta ese momento, el pretor se habría limitado a ejercer su *iurisdictio* en la nueva forma del procedimiento formulario sólo para tutelar relaciones jurídicas consagradas por el

ius civile o fundadas en la *bona fides* como criterio obligatorio sancionado por su colega peregrino. En ambos casos se trataba de normas ya existentes, ya consagradas antes de su intervención. Pero el camino estaba abierto para una más libre, más audaz actuación: su *imperium* no estaba trabado por el formalismo de las *legis actiones* y de su arbitrio dependía la existencia y el contenido de la fórmula, que era ley para el juez.

V. El pretor, en posesión de todos los recursos procesales y extraprocesales, se lanzará a una labor de profunda renovación, creación y desarrollo de instituciones jurídicas que convertirá a la *iurisdictio* en la fuente más original del Derecho Romano.

Con la *denegatio * actionis* y la inserción de *exceptiones* * paralizará pretensiones basadas en principios ya obsoletos o chocantes del viejo *ius*; con las acciones ficticias * o las útiles o las con transposición de sujeto podrá extender a situaciones antes no previstas la aplicación de normas ya existentes; por último, hasta podrá dar lugar, con las *formulae in factum conceptae* *, a la tutela de situaciones o relaciones hasta entonces no consideradas en el ordenamiento jurídico existente.

VI. La decadencia de las *legis actiones* —dejadas de lado por su formalismo y poca flexibilidad de adaptación a las características propias de cada controversia— se patentizará con la *lex Iulia iudiciorum privatorum* de Augusto, que las suprime casi totalmente y las sustituye con el sistema de las fórmulas, al que “legaliza” en el sentido de que, de ahí en adelante, todo juicio —sea basado en instituciones del antiguo *ius civile*, sea en la *bona fides*, sea en una situación fáctica digna de tutela por razones de equidad— será considerado *iudicium legitimum*, siempre que se den estas tres condiciones —no de fondo, sino de forma procesal—: que las partes sean ciudadanos romanos, que se celebre en Roma y que el arbitraje se someta a un único juez.

DESARROLLO DEL PROCESO

CITACION

La citación a comparecer en justicia, con previa exposición verbal del reclamo, podía ser, igual que antes, con una *in ius vocatio* de efecto inmediato, pero se hizo más frecuente el *vadi-monium*, compromiso —a través de una *stipulatio*— de comparecer en determinada fecha ante el tribunal.

LAS PARTES

En el procedimiento formulario —y luego en el extraordinario— se admitió un tipo de representación* distinta de la actual, pues quien sustituía a cualquiera de las partes experimentaba en su persona los efectos del proceso: resultaba acreedor o deudor en la *condemnatio* y era consecuentemente sujeto activo o pasivo de la ejecución a través de la *actio iudicati*.

- * Esto se traducía procesalmente en el hecho de figurar en la *intentio* el nombre de la parte y en la *condemnatio* el del representante.
- * No obstante ello, por razones prácticas, el pretor concedió la *actio iudicati* tanto para, como contra, la persona misma del acreedor o deudor, respectivamente.

Uno y otro pudieron ser sustituidos o representados por un *cognitor* y por un *procurator*.

- * El *cognitor* debía ser instituido en términos solemnes en presencia de la otra parte.
- * El *procurator*, generalmente un intendente o gerente de los bienes y negocios de su representado, o el *procurator ad litem*, específicamente designado para el juicio en cuestión, podían tomar su papel sin solemnidades y aun sin conocimiento de la parte contraria.
- * Se llamó *defensor* a quien espontáneamente y de buena fe tomaba la representación de un demandado sin mandato de éste. Debía dar caución de que el demandado ratificara lo por él actuado.

ETAPA IN IURE

I. Presentadas las partes ante el magistrado, el demandante planteaba su pedido de acción sobre la base de una fórmula

que proponía. El demandado concordaba con el planteo o im-postación jurídica insita en la fórmula propuesta, o reclamaba alguna alteración —especialmente la inserción de una excepción—. El magistrado establecía en qué términos daría el *iudicium* y llevaba a las partes a un acuerdo en la redacción de la fórmula y en la elección del juez.

II. Se tiene, entonces, la *litis contestatio*, concretada en una formal propuesta y aceptación, de demandante y demandado respectivamente, de someterse al juicio en los términos en que se hallaba redactada la fórmula, la que, como se verá, incluía la orden del magistrado al juez para que, según las pruebas recibidas, condenara o absolviera al demandado.

III. Con la *litis contestatio* quedaban determinados en forma precisa y fija los derechos subjetivos deducidos en juicio.

Las obligaciones civiles en un *iudicium legitimum* se extinguían con la *litis contestatio*, o más exactamente se transformaban en una relación procesal, de modo tal que si el demandado resultaba absuelto, el demandante no podía volver a replantear en otro juicio aquella obligación, extinguida, como se ha dicho, por la *litis contestatio*. Si, en cambio, resultaba condenado, tampoco podía volver a accionar el actor en base a esa obligación, por ese mismo carácter extintivo de la *litis contestatio*; pero sí tenía derecho a actuar en base a la nueva relación creada por la *condemnatio* y posibilitada por esa relación o compromiso procesal de la *litis contestatio*.

En cambio, la *litis contestatio* no producía la extinción de los otros derechos litigiosos deducidos en juicio, pero sí daba lugar a una excepción de *litis pendencia* en cualquier otra causa en que se los planteara nuevamente.

ETAPA APUD IUDICEM

No presenta mayores diferencias con la de las *legis actiones*: el juez, asistido de un *consilium* de amigos, recibe en lugar público la producción de pruebas y los eventuales alegatos de oradores de una y otra parte. Con completa libertad para va-

47

504 1

lorar la prueba, llega a la formulación de su parecer (*sententia*) ante las partes.

- Si no ha podido llegar a un convencimiento o decisión, jura que el caso no es claro para él (*sibi non liquere*) y el magistrado lo libera de su cargo. Las partes conciertarán entonces, con el magistrado, el nombramiento de otro juez.

LA EJECUCION

Para conseguirla, el demandante victorioso deberá, sin embargo, introducir una nueva acción: la *actio iudicati* (acción de lo ya juzgado). Si en la etapa *in iure* el demandado admite su responsabilidad, queda abierta la ejecución. Pero si quiere controvertir, no por cierto el mérito de la causa sentenciada, sino alguna invalidez de forma, o sostener que ya ha pagado, habrá, entonces una nueva *litis contestatio* y etapa *apud iudicem*: la condena, en este caso, será ejecutiva por el doble de lo estatuido en el primer juicio.

- La ejecución sobre la persona del deudor —*manus iniectio*— subsistirá, pero se la irá sustituyendo con un procedimiento de ejecución sobre la totalidad del patrimonio —*bonorum venditio*— que recuerda en algo los actuales procedimientos de la quiebra.

LA FORMULA

Con este nombre se denominó el programa o planteo de juicio —con la correlativa enunciación del deber del juez—, ya sea en su aspecto abstracto, como esquema propuesto en el edicto, ya sea en un aspecto concreto, como formulación ya aprobada por el pretor en un determinado proceso.

La fórmula coordina y da unidad a las dos etapas del proceso.

La estructura de la fórmula refleja esa función. Puede

comprender las siguientes partes o cláusulas, que cuando aparecen, lo hacen en el orden en que a continuación se las consigna.

1) Nombramiento del juez o de la corte o colegio de recuperadores.

2) *Praescriptio*. Como su nombre lo indica —lo escrito al principio—, es una cláusula extraordinaria que se coloca —antes de cualquier otra referencia a la controversia— con el objeto de limitar o descartar los efectos de la *litis contestatio* articulada en el resto de la fórmula. Ejemplo, la orden al juez de que, previamente a entrar en materia, verifique si no ha vencido el plazo establecido por la ley para que una determinada acción pueda interponerse. De allí proviene el nombre de la actual prescripción. Otro ejemplo: si se trata de accionar por prestaciones sucesivas en el tiempo, el actor —para preservar la posibilidad de reclamar las futuras, que de otro modo serían extinguidas por la *litis contestatio*— delimita el objeto de su *intentio* a las que resulten vencidas o exigibles en el momento de la *litis contestatio*. Para ello inserta como *praescriptio* la frase "*ea res agatur, cuius rei dies fuit*" ("que el pleito sea por lo que resulte ya debido").

3) *Demonstratio*. En ciertas fórmulas suele resultar necesaria para enunciar los hechos en que se basa el derecho que se alega. Por ejemplo: "Ticio, sé juez. Puesto que Aulo Agerio ha vendido un esclavo a Numerio Negidio, respecto del cual se litiga..."

4) *Intentio*. Parte esencial que consiste en la enunciación de la relación jurídica deducida en juicio. Por ejemplo: "Ticio, sé juez. Si resulta que el fundo cornelianus es de Aulo Agerio..." Es, en otros términos, la pretensión del actor presentada como condición para la *condemnatio*.

5) *Exceptio*. Cláusula cuyo efecto es impedir al juez condenar, aun si resulta probada la *intentio*, si otras circunstancias de hecho o situaciones de derecho aparecen también probadas. Va introducida por una expresión como "siempre que no", "a no ser que". Por ejemplo: "Si resulta que Numerio Negidio debe pagar a Aulo Agerio mil sestercios y siempre que no haya habido un pacto de no reclamar esa deuda..."

Las excepciones se dividen en perentorias —basadas en una circunstancia oponible siempre a la acción del actor— y dilatorias —oponibles sólo en un cierto período de tiempo o frente a determinadas personas—; el último ejemplo citado, según el pacto sea de no reclamar nunca, o sólo por un tiempo, respectivamente.

6) *Adiudicatio*. Cláusula por la que se autoriza al juez, en las acciones por división o partición de bienes, a adjudicarlos en pleno dominio a quien resultaren corresponder.

7) *Condemnatio*. Cláusula por la que se da al juez el poder de condenar o de absolver. La condena, cualquiera haya sido lo reclamado, será siempre por una cantidad de dinero ya fijada en la *condemnatio*, o a fijar por apreciación del juez.

En síntesis, la fórmula es una orden al juez planteada más o menos en este sentido: "Si resultan verdaderos los hechos expuestos en la *demonstratio* y si resulta fundada la pretensión expuesta en la *intentio*, y siempre que no resulte verdadera la circunstancia de hecho o situación de derecho planteada en la *exceptio*, condena, entonces, juez, al demandado a pagar determinada, o a determinarse, suma al actor; si no resultan verdaderos aquellos hechos, o fundada aquella pretensión, o resulta positivo lo planteado en la *exceptio*, absuelve al demandado".

CLASES DE FORMULAS

Según la inexistencia, o el mayor o menor grado de apoyo en el *ius* que tenga cualquier tipo de fórmula instrumentado por el magistrado, se puede hacer la siguiente distinción.

A) Fórmulas con *intentio in ius concepta* (*intentio* basada en derecho).

1) Fórmulas en las que se han vertido las preexistentes acciones del *ius civile*. En ellas el magistrado ha tendido a la

simplificación y a una mejor adaptación a los distintos aspectos de hecho o de valoración: con *exceptiones* y *praescriptiones* corrigió el rigor y formalismo del antiguo *ius* y dio relevancia jurídica a situaciones y modalidades antes no contempladas en el ordenamiento normativo.

2) Fórmulas en las que se extiende el campo de acción de las preexistentes acciones del *ius civile*.

a) Fórmulas ficticias, en las que se ordena al juez que prescinda de la existencia o no existencia de determinada condición o circunstancia y dé su sentencia como si no existiera o existiera respectivamente. Un ejemplo a propósito de la propiedad bonitaria *: "Ticio, sé juez. Si Aulo Agerio compró y le fue entregado [sin *mancipatio* *] el esclavo Stichio, que, si lo hubiera poseído un año, sería suyo según el *ius quiritium*, y a pesar de tu decisión, Numerio Negidio no lo hubiera restituido a Aulo Agerio, condena a N.N. a pagar a A.A. tanto dinero como valga la cosa, y si no ha resultado así [la cuestión], absuévelo". Aulo Agerio no ha tenido un año de posesión para poder llegar por *usucapio* a ser dueño del esclavo, pero se le indica al juez que asuma ficticiamente que ha tenido lugar ese lapso y discrimine, en cambio, las otras condiciones que posibilitan la *usucapio* *.

b) Fórmulas útiles, por las que se extiende el alcance de instituciones del *ius civile* a sujetos o situaciones no comprendidos primitivamente. Un ejemplo lo encontramos en la facultad otorgada al comprador en bloque del patrimonio de un deudor —*bonorum venditio* *— de ejercitar, precisamente como útiles, todas las acciones que le competían a éste.

c) Fórmulas con transposición de sujetos. Mediante ellas se superó, por ejemplo, la antigua imposibilidad de obligar al *pater* por deudas contraídas por el *filius* con motivo de la administración del peculio *: en la *intentio* figuraba el nombre del *filius*; en la *condemnatio*, el del *pater*, al que por principios de conveniencia y equidad se quería responsabilizar.

(B) Fórmulas *in factum conceptae* (basadas en situaciones de hecho). Con ellas el magistrado tutelaba situaciones de hecho no contempladas todavía por el *ius* preexistente, pero que en

virtud de la *aequitas* y la conveniencia social le resultan dignas de amparo. Las tiene, pues, previstas en su edicto o, si no las ha previsto, las concede por *decretum repentinum* en los casos concretos en que encuentra mérito.

- | | | | | |
|--|---|---|---|--|
| (A) Fórmulas con <i>intentio</i>
in <i>ius concepta</i> | { | 1) Fórmulas para preexistentes acciones civiles | { | a) Fórmulas ficticias |
| | | 2) Fórmulas extensivas del <i>ius civile</i> | | b) Fórmulas útiles
c) Fórmulas con transposición de sujetos |
| (B) Fórmulas <i>in factum conceptas</i> | | | | |

CLASIFICACION DE LAS ACCIONES

La vastísima variedad de las fórmulas marca un fuerte contraste con la limitación y rigidez de las *legis actiones*.

Cada fórmula, como esquema abstracto de juicio entraña un determinado tipo de *actio*. En el edicto del magistrado, pues, figuran tantas acciones —cuyos términos se dan en otras tantas fórmulas— cuantas son las situaciones o intereses subjetivos considerados dignos de amparo judicial. De allí que acción, desde el punto de vista del sujeto, es el poder, para quien se encuentra efectivamente en una de esas hipotéticas situaciones, de actuar según el esquema procesal específicamente correspondiente.

El proceso formulario gira alrededor de un repertorio de acciones típicas mediante el cual el pensamiento jurídico romano estructura el sistema de lo que para nosotros son los derechos

subjetivos. Ese repertorio aparecía clasificado por los juristas según distintos criterios.

ACTIONES CIVILES - ACTIONES HONORARIAE

Las primeras, fundadas estrictamente en el *ius civile* preexistente, son las involucradas en las fórmulas aludidas como (A) 1) en el título Clases de fórmulas.

Las segundas, dispuestas por el magistrado en el ejercicio de su cargo (*honor*) para tutelar una relación no contemplada expresamente en el *ius*, son las que se dan en las fórmulas comprendidas en (A) 2) a), b), c) y (B) del mismo título.

ACTIONES IN REM - ACTIONES IN PERSONAM - MIXTAE

A través de la distinción procesal entre acciones *in rem* e *in personam* el pensamiento romano formulaba lo que para nosotros es la teoría de los derechos reales y obligaciones.

Las acciones *in rem*, llamadas también *vindicationes*, cuando son dadas en tutela de un derecho real, reclaman del demandado una determinada conducta negativa: la reclamación es posible con respecto a cualquier persona si se trata del derecho de propiedad, y sólo respecto a determinadas si se trata de un derecho real sobre cosa ajena, específicamente, las determinables por una relación con esa cosa.

Pero también las acciones *in rem* sirven para pretender el reconocimiento de otras situaciones no patrimoniales, como son las de estado; por ejemplo, que se es hijo legítimo.

• En la *intentio* sólo figura, proclamado en forma absoluta, el derecho sobre la cosa, y sólo en la *condemnatio* aparece la designación del demandado.

Las acciones *in personam*, llamadas también *condictiones*, protegían un derecho subjetivo obligacional. Ya en la *intentio* figuraba el actor pretendiendo del demandado una determinada conducta, esto como resultado del vínculo de derecho existente entre ellos.

Las mixtas son aquellas con las que se pretenden atribuciones de derechos reales y de derechos obligacionales.

- * Son las acciones divisorias *familiae erciscundae* (división del patrimonio familiar), *communi dividundo* (división de un condominio) y *finium regundorum* (demarcación de límites): el juez con la *adjudicatio* * puede constituir no sólo derechos reales sino también obligaciones entre las partes.

ACTIONES STRICTI IURIS - ACTIONES BONAE FIDEI - ACTIONES IN BONUM ET AEQUUM CONCEPTAE

Según la amplitud del poder otorgado en la fórmula al juez, se distinguen las acciones *stricti iuris* (de estricto derecho), en las que aquél debe restringirse a lo indicado en la *intentio*, y eventualmente la *demonstratio*; y las *bonae fidei*, en las que la expresión *ex bona fide* (en base a la lealtad o buena fe), contenida en la *intentio*, autoriza al juez una ampliación en su poder de apreciación y sentencia al indicarle tenga en cuenta criterios de equidad y buena fe en las relaciones entre las partes, relaciones previas al proceso y debidas, por ejemplo, a contratos consensuales *, a la fiducia *, a la tutela *, a la gestión de negocios *, etcétera.

No resulta claro si a estas últimas acciones se asimilan plenamente las *in bonum et aequum conceptae* (basadas en lo adecuado y justo), cuya fórmula ordena al juez determinar el monto de la condena según la equidad.

ACTIONES REIPERSECUTORIAE - ACTIONES POENALES - ACTIONES MIXTAE

Son acciones que se distinguen según el fin perseguido. Las *reipersecutoriae* buscan la estricta reparación de la pérdida o daño sufrido.

- * Son reipersecutorias tanto las reales por las que se reclama la restitución de un objeto —acción reivindicatoria, *hereditatis petitio*, etcétera— como las personales por las que se reclamaba una cantidad de dinero en base a un contrato o como reparación por un daño patrimonial producido por un acto ilícito.

Las *poenales* persiguen el pago de una pena pecuniaria, como es el caso de la *actio furti* *.

Las *mixtae* tienen uno y otro objetivo: por ejemplo las acciones derivadas de la ley *Aquiliana* *.

ACTIONES ARBITRARIAE

Son aquellas cuya fórmula contiene la cláusula "*nisi arbitratu iudicis restituatur*" (a no ser que, por lo dispuesto por el juez, sea restituido), que supedita la condena pecuniaria a la no restitución o no exhibición de la cosa.

- * El demandado perdedor puede en ese caso retener válidamente la cosa y pagar la *litis aestimatio* fijada por el juez, a menudo de acuerdo a juramento estimatorio del actor, y siempre mayor que el valor de la cosa.

ACTIONES PERPETUAE - ACTIONES TEMPORALES

Al principio no había límite temporal para el ejercicio de las acciones. Pero luego algunas acciones fueron consideradas extinguidas si no se deducían en un determinado plazo a partir del momento en que había nacido la posibilidad de ejercitarlas: el plazo de un año, por ejemplo, para la mayoría de las acciones honorarias. Hubo así una distinción entre acciones perpetuas y temporales.

Pero a fines del Principado se admitió que el demandado por una *actio in rem* pudiera oponer la *exceptio* o la *praescriptio longi temporis* haciendo mérito de haber poseído la *res* por un período de diez años, si el poseedor demandado y el actor, pretendido titular, vivían en el territorio de la misma *civitas*, o de veinte si no era así.

En el 424 a.C. Teodosio II extendió ese criterio a todas las acciones consideradas hasta ese momento perpetuas: todas quedaban extinguidas al no ser deducidas dentro de un plazo de treinta años, aunque la Iglesia tuvo el privilegio de que en relación a los bienes de que era titular las acciones tuvieran una prescripción de cuarenta años.

No obstante, se siguió llamando perpetuas a las prescripti-

49

504 1

bles a los treinta o cuarenta años, y temporales a las de prescripción más breve.

MEDIOS EXTRAPROCESALES

Basados no en su *iurisdictio**, sino directamente en su *imperium**, completan la capacidad innovadora del magistrado en el campo jurídico.

(A) STIPULATIONES PRAETORIANAE

Obligando a una parte a que, por medio de una *stipulatio**, asegure a la otra un derecho o una compensación, el pretor cubre lo que, de acuerdo con la *aequitas*, es un déficit del ordenamiento jurídico. Ejemplo, la *cautio damni infecti**.

(B) IN INTEGRUM RESTITUTIO

Un total restablecimiento de la situación anterior. Por ella el pretor anula las consecuencias que han resultado inequitativas de un acto válido según el *ius civile*. Tal la otorgada a los *minores** de 25 años.

(C) MISSIONES IN POSSESSIONEM

Autorizaciones del pretor para que alguien entre en posesión de un bien, o del total, o cuota parte patrimonial de otra persona. Esa posesión varía en sus efectos, desde participar, con currentemente con el original poseedor, en el manejo de la cosa, hasta permitirle al nuevo poseedor una eficientísima y protegida posesión capaz de llevarlo a una *usucapio**. Y sus propósitos van desde presionar a una parte para inducirle a una determinada conducta —por ejemplo, hacer una *stipulatio praetoriana*— hasta colocar a una persona en condiciones de adquirir una cuota o la totalidad de los bienes de una sucesión *mortis causa*, a pesar de no ser heredero de acuerdo al *ius civile*.

(D) INTERDICTA

Órdenes condicionales que da el pretor, a pedido de parte interesada, a persona determinada para que restituya o exhiba algo o se abstenga de un proceder. La no aceptación de tales órdenes, sobre la base de que no se dan las condiciones, lleva a un proceso frente a un *iudex* o a *recuperatores*.

EL EDICTO

Las soluciones que se iban plasmando en las concretas fórmulas con que se otorgaba el *iudicium* se consignaban en el edicto que cada magistrado publicaba al asumir su cargo anual.

Cada nuevo pretor, haciendo suya la experiencia de sus predecesores, trasladará a su propio edicto el contenido de los anteriores (*edictum translatitium*) e incorporará de su cuenta, elementos nuevos.

El edicto es un programa de cómo desarrollará su jurisdicción el pretor; es el compromiso —controlado siempre por una vigilante opinión pública y, desde el 67 a.C., sancionado por la *lex Cornelia*— de, según las hipótesis contempladas, dar acciones, permitir inserción de excepciones, disponer de sus recursos extraprocesales, etcétera. El edicto es, en lo fundamental, un catálogo de fórmulas en el que se puede seleccionar la que corresponderá —si el pretor estuviera de acuerdo— como base del *iudicium* que se le habrá solicitado para dirimir una controversia.

* En el edicto no hay normas imperativas ni para las personas —ni se crean directamente— ni para las instituciones, pues el pretor no es legislador; pero a través de la promesa de medios procesales o extraprocesales, se induce la sanción de una determinada relación jurídica. Así, por ejemplo, si el pretor en su edicto prometía conceder una acción contra el acreedor que, una vez satisfecho en su crédito, no restituyera

81

un bien prendado en garantía de aquel crédito, no estaba creando directamente una obligación de restituir, que, por lo demás, no existía todavía en el *ius civile*. Pero, toda vez que el acreedor se sabía expuesto a una acción y a la correspondiente sentencia, puede decirse que indirectamente se sentía "obligado", en este caso por el *ius honorarium*.

- Por lo tanto, en la práctica no había que consultar repertorios de leyes o de jurisprudencia: lo importante era encontrar en el edicto la fórmula que ofrecía el pretor, específicamente en consideración a la relación fáctica —no prevista por el *ius*— o jurídica —reglada por el *ius*— en la que una persona se encontraba.
- Por todo ello va a resultar fundada aquella afirmación de que el Derecho Romano —por lo menos en su mejor momento— aparece más como un sistema de acciones que como un elenco de derechos subjetivos explícitamente originados en el derecho objetivo.

EL SISTEMA EXTRA ORDINEM

El proceso cognitorio se caracteriza por su carácter público, estatal, frente al de arbitraje privado —sólo encuadrado y reglado por el pretor— que presenta el formulario: no interviene un juez privado sino un juez funcionario, delegado mediano o inmediato del emperador. Se llamó procedimiento extraordinario porque no aparecía la típica bipartición que había sido desde los orígenes de Roma propia del orden o estructura de los juicios privados.

- La *cognitio extra ordinem* no implicaba, necesariamente, que el magistrado o funcionario tratara todo el asunto por sí solo. Se podían dar estas tres posibilidades: a) su intervención total en un proceso unitario; b) delegación completa a otra persona, particular, magistrado o funcionario subordinado; c) *cognitio* en la que puede llegar hasta haber, como en el procedimiento ordinario, dos etapas: en la primera, redacción de una fórmula y la consiguiente *litis contestatio*; en la segunda, actuación de un funcionario que, en este caso, recibe su poder del magistrado o funcionario delegante, y no como consecuencia de un arbitraje querido por las partes.
- El sistema procesal se adecua así al nuevo régimen político que se inicia con el Principado y culmina en el Dominado: un poder autocrático, cabeza de una creciente y prolija burocracia que interviene cada vez más en todos los aspectos —social, económico, cultural— de la vida comunitaria.
- De todos modos, con el sistema *extra ordinem* tomó cuerpo la idea de que la administración de justicia es atributo del estado, en contraposición con la tradicional postura romana de que la función del estado era,

a través del magistrado, sólo regular y moderar un proceso actuado por iniciativa, impulso y voluntad de las partes.

HISTORIA

I. La actuación *extra ordinem* del magistrado se conocía en el ámbito administrativo ya desde los tiempos republicanos. Los romanos no podían concebir que el *populus romanus* pudiera entrar en una relación jurídica en plano de igualdad con los particulares. En una reclamación contra el estado, el particular no podía pretender un juicio ordinario. Debía dirigir su reclamación al magistrado correspondiente —a menudo el mismo que había cumplido el acto cuestionado— para que éste, atendidas las razones —*causa cognita*—, decidiera, sin más, la cuestión.

II. Además, ese modo de actuar era el normalmente aplicado en las provincias que formaban el Imperio. Allí los magistrados romanos tenían plena *iurisdictio*, que comprendía el entender totalmente en las controversias y emitir sentencia.

III. Esta modalidad de intervención en la que el magistrado conocía y resolvía en unidad de actuación se extendió durante el Principado, fundamentalmente por tres causas: 1) el emperador fue encargando a magistrados la tutela de ciertas situaciones que hasta el momento no originaban más que obligaciones de tipo moral y que ahora se quería hacer coactivo su cumplimiento: por ejemplo, los fideicomisos y la obligación de alimentos; 2) la creciente extensión del ámbito de competencia de los funcionarios creados por el emperador hizo que le incumbiera la resolución de numerosos litigios y controversias a propósito, por ejemplo, del acaparamiento y comercialización de granos, locaciones urbanas, posesión de tiendas en la vía pública, etcétera; y 3) la delegación de su *iurisdictio* —por indefinida, precisamente más ilimitada— que fue haciendo el emperador en casos esporádicos, al principio, y luego con asignación de competencias permanentes.

IV. El proceso formulario, ya en decadencia a fines del Principado, terminó completamente cuando los emperadores Cons-

50

50441

tantino y Constante en el 342 a.C. prohibieron el uso de fórmulas al considerarlas peligrosos y rebuscados juegos de palabras. Pero su arsenal de medios técnicos fue, sobre todo por Justiniano, utilizado para implementar el nuevo tipo de proceso basado en esa *cognitio extraordinaria* del período clásico, y que ahora había pasado a ser ordinario.

DESARROLLO DEL PROCESO

CITACION

La citación a juicio dejó de ser una actividad que correspondía al demandante para ser una orden de comparecencia decretada por el oficial público con la alternativa de, en caso de no presentación del demandado, declararlo contumaz y seguir el juicio en rebeldía.

No había más, pues, aquel carácter convencional y arbitral del proceso formulario, donde las partes se ponían de acuerdo, bajo la dirección del pretor, en los términos de la controversia y en la elección de un juez privado.

- Desde el 322 a.C. ya era obligatoria la *litis denuntiatio*: en un *libellus denuntiatio*, el actor presentaba su pretensión y solicitaba al tribunal competente se diera curso a la instancia. Si el juez, tras un breve examen, encontraba seria la *denuntiatio*, la comunicaba por un agente del tribunal al demandado, quien, en un plazo máximo de cuatro meses, debía depositar en el tribunal su *libellus contradictorius*. Si no lo hacía, el proceso continuaba en contumacia.

ACTUACION JUDICIAL

Comparecidas las partes o sus representantes en el día fijado, se planteaban en la audiencia, con la intervención de los *advocati* (llamados en consulta), las distintas posturas que llevaban a la formulación o definición de la controversia; eso constituiría la *litis contestatio*, que ya no tenía el efecto extintivo que se daba en el procedimiento formulario. En audiencias sucesivas se producía la prueba con juramentos, testimonios, documentos, etcétera.

- El desenvolvimiento del proceso era desprovisto al máximo de formalidades: rara vez se presentaban escritos, pero la secretaría del tribunal sintetizaba en actas las actuaciones orales. La lucha argumental entre las partes —precisamente por la falta de una previa impostación o reglaje de la *litis* que limitara el campo controvertido— se prestaba a toda sorpresa y argucia, por lo que se hacía sentir más que antes la necesidad de abogados para asistir a las partes. El juez funcionario apreciaba las cuestiones de hecho —recibía personalmente la prueba— y de derecho, aunque ya vimos que podía delegar algunas funciones a *iudices pedanei* (jueces sentados a sus pies, es decir, subordinados).
- Característica del nuevo proceso es el deber del juez de sujetarse a criterios determinados para la valorización de las pruebas; así se patentiza con las *praesumptiones*, que le significan la obligación de deducir de un hecho cierto la existencia de otro incierto o no probado; al que se le atribuyen consecuencia jurídicas.
- Las presunciones son: *iuris et de iure* (de y por derecho), en las cuales no se admite la prueba contraria a la existencia del hecho presumido o deducido; o *iuris tantum* (sólo de derecho), en las cuales se admite dicha prueba.

SENTENCIA

Terminados los alegatos, analizados los resultados de la *inquisitio*, a veces con buen acopio de presunciones, el juez emite su *sententia* leyéndola a las partes.

La sentencia, si no era absolutoria, consistía —contrariamente a lo que ocurría con la condena pecuniaria del sistema formulario—, de ser posible, en la condena de la precisa prestación debida más las expensas procesales.

Aquel efecto de la *litis contestatio* de extinguir los derechos obligacionales deducidos en juicio lo tiene ahora sólo la sentencia: mientras ella no sea pronunciada se puede iniciar otro juicio basado en la misma pretensión.

APELACION

La actividad jurisdiccional del emperador, sumada a su enorme *auctoritas**, no podía menos que hacer que los particulares derrotados en un juicio se sintieran tentados a someterlo a su alta revisión. Nació así la institución de la apelación, que se extendió también a otras instancias de la jerarquía burocrática.

Antes, en el sistema formulario, uno sólo podía poner en

cuestión un fallo defendiéndose al ser demandado en la consecuente *actio iudicati* *. Ahora, en cambio, contra toda sentencia que no fuera en contumacia se podía apelar a una nueva autoridad superior, que volvía a examinar la causa.

EJECUCION

En la *cognitio extraordinaria*, el magistrado o funcionario puede hacer ejecutar su decisión por directa coacción de la fuerza pública. Es posible la prisión por deudas, pero se acostumbra un más ágil y conveniente sistema de ejecución sobre los bienes que en la *bonorum venditio* *: personal del tribunal puede ser autorizado a tomar una parte suficiente del patrimonio del deudor y luego de dos meses venderlo para satisfacer al acreedor.

CAPITULO IX

DERECHOS REALES

CONCEPTO DE DERECHOS REALES

Se ha visto que los derechos patrimoniales se distinguen en dos categorías fundamentales: derechos reales y personales u obligacionales.

Suele caracterizarse al derecho real como un señorío inmediato —es decir, sin la intermediación de otra persona— sobre una cosa. Se habla también de una directa relación entre el sujeto y la cosa, en contraposición con el derecho personal, consistente en una relación entre dos personas determinadas, un sujeto activo —porque le compete una acción— y otro pasivo —porque le toca padecer el ser constreñido al cumplimiento de una prestación.

No hay coincidencia en la doctrina en una precisa definición de ambas categorías de derechos; se hace notar, por ejemplo, que no puede haber relación jurídica entre un sujeto y un objeto, sino necesariamente entre personas; que lo que hay en el derecho real es un señorío, más o menos absoluto o limitado, sobre una cosa, posibilitado por una área de libertad de acción que, por la norma jurídica, están obligados a respetar todos los demás miembros de la comunidad. En lugar de entrar en las distintas teorías, se prefiere aquí explicitar algunas diferencias entre derechos reales y personales.

SI

504 1

DERECHOS REALES

DERECHOS PERSONALES

La relación jurídica

Entre titular y todos los otros miembros de la comunidad.

Entre sujeto activo y pasivo de una obligación.

De quién se espera el deber que cumplimente el derecho subjetivo

Sujeto pasivo indeterminado: todos constreñidos a un deber genérico de abstención. Ese deber se hace específico en el caso de los derechos reales sobre cosa ajena: los sujetos pasivos, entonces, quedan determinados por su actual relación con la cosa: por ejemplo, los sucesivos dueños de un fundo sirviente.

Persona determinada desde el nacimiento del derecho, al quedar como sujeto pasivo por obligación originada de contrato, responsabilidad por acto ilícito, ley, etcétera.

Contra quién se puede accionar

Contra quien, eventualmente, interfiera en el ejercicio del señorío. La pretensión abstracta *erga omnes* (contra todos) se traduce o concreta en un poder de accionar contra el individualizado desconocedor o violador del derecho real.

Contra el deudor que no cumple en su oportunidad la prestación.

Objetos

Cosas necesariamente determinadas y de existencia actual.

Pueden ser indeterminados. Se trata de actos ajenos que tienen interés patrimonial. En última instancia, gravitan sobre la masa patrimonial, prenda común de los acreedores.

Cómo es la relación con el objeto

Inmediata, sin necesidad de colaboración activa de ningún sujeto.

Mediata, a través de un dar, un poner a disposición, un hacer o una específica abstención del sujeto pasivo.

Oponibilidad

Absoluta, persecutoria y prioritaria o preferencial contra quienes adquieran con posterioridad cualquier derecho real sobre la misma cosa.

Relativa sólo al deudor y a sus herederos y concurrente con los otros créditos que obliguen al mismo deudor.

Estructura y contenido

Debidos al ordenamiento vigente y no modificables por la voluntad de las partes.

Según las libres convenciones de las partes.

Tipos

Sólo los taxativamente previstos por el derecho objetivo.

Tan variados como la imaginación pueda sugerir dentro de los límites de la licitud jurídica y moral.

Extinción

Por acto unilateral —abandono*

Por los modos explicados en el capítulo "Efectos y extinción de las obligaciones".

Ventaja económica

No se agota por el ejercicio del derecho: éste y la posibilidad de provecho tienen la misma duración.

Es un derecho de expectativa: se concreta la ventaja económica en el momento del cumplimiento de la prestación; se agota, entonces, el derecho.

Función económica

Apropiación y disfrute de los bienes.

Organización jurídica de los servicios.

GENESIS DE LOS DERECHOS REALES

I. La doctrina romana no presenta ni una elaboración dogmática ni una terminología técnica unitaria para los derechos reales desde el punto de vista del derecho sustancial. Acostumbrados a analizar los fenómenos jurídicos en su dinámica procesal, dieron comienzo a la actual discriminación con su oposición entre las acciones reales y las personales.

II. Desde el principio la *vindicatio* o acción real se identificó con el primer derecho real, el *mancipium**, poder unitario y absoluto del *paterfamilias*.

De ese derecho real absoluto se irán desglosando poderes y derechos sobre personas y cosas de la familia: también ellos serán tutelados con acciones reales.

III. Los derechos llamados posteriormente *iura in re aliena* (derechos en cosa ajena) no tienen otra definición unitaria que la de ser derechos reales limitados: reales por la acción *in rem* y limitados porque abarcan sólo una parte específica del bloque de facultades constituido por el dominio.

IV. Esos derechos reales brotaron no sistemática, sino em-

piricamente, de acuerdo con las necesidades socioeconómicas, y lo que los caracterizó fue —aparte de aparecer como un recorte sobre el ilimitado señorío primitivo del *mancipium*— que, por razones pragmáticas y no dogmáticas, se les fue concediendo la eficacia de una *actio in rem* —*vindicatio*— con una progresiva extensión *erga omnes* (frente a todos), que en los comienzos sólo se concebía para el dominio o propiedad.

V. Los primeros de esos derechos fueron las servidumbres rústicas, consideradas, ya de antiguo, *res mancipi*; luego las urbanas. También antiguos son el usufructo y el uso, convertidos en reales al ser dotados de una acción *in rem*: con ellos y los derechos de *habitatio* y *operae servorum* de la época justiniana la doctrina elaboró el concepto de servidumbres personales. Del derecho honorario se originará el *ius in agro vectigali* (derecho real sobre tierra pública), que será absorbido por el de enfiteusis, que al igual que la *superficies*, es de la época posclásica. También de origen honorario, tomarán cuerpo los derechos reales de prenda e hipoteca, considerados como de garantía, en contraposición a los otros de uso y goce, porque no proporcionan otra ventaja económica que la de garantizar una obligación.

DERECHOS REALES

Absolutos	Propiedad o dominio.		
Limitados o <i>iura in re aliena</i>	Servidumbres prediales	Rústicas	De uso y goce
		Urbanas	
	Servidumbres personales	Usufructo	
		Uso	
		<i>Habitatio</i>	
		<i>Operae servorum</i>	
	<i>Superficies</i>		De garantía
	<i>Enfiteusis</i>		
	Prenda		
	Hipoteca		

LA PROPIEDAD

Los regímenes de apropiación y disfrute de los bienes no se han estructurado en todos los pueblos de la misma manera.

Nuestra noción de propiedad alude a la creación romana en ese campo, creación que se ha transmitido al occidente y al mundo entero en la medida en que éste se ha occidentalizado.

La propiedad, más que definida, intuida en esa versión romana, se presenta como el potencialmente más pleno y absoluto señorío jurídico sobre una cosa corporal.

- Señorío, porque hay un poder directo e inmediato sobre la cosa que en su origen histórico y en su designación —*mancipium*, *dominium*— tiene un contenido, o al menos un reflejo, de soberanía política.
- Jurídico, no porque —como es obvio— el derecho objetivo lo sanciona y protege, sino por su carácter ideal, que puede prescindir del efectivo poder o control sobre la cosa, contrariamente a lo que ocurrirá con la posesión, que requiere un efectivo poder de hecho.
- Potencialmente más pleno y absoluto, por la plenitud de facultades, que no se agota en una enumeración y que se presenta como un todo unitario potencialmente entero, aunque, de momento, el ordenamiento jurídico o la voluntad de los titulares haya desglosado o limitado algunas de esas facultades.
- Sobre cosa corporal, porque era extraña a los romanos la idea de una propiedad sobre inmateralidades, como ser una creación de la imaginación: invento científico, obra literaria, nombre comercial, etcétera.

CARACTERES

El dominio o propiedad romana presenta los siguientes caracteres, resultado de las modalidades de su génesis y desarrollo históricos.

ABSOLUTA

No porque no pueda haber limitaciones, sino porque todas las facultades del titular que no están taxativamente prohibidas o limitadas quedan indeterminadas e infinitas. Resultado de ese carácter es la modalidad elástica del derecho de propiedad: si su contenido, verdadero bloque unitario de indeterminadas e in-

finitas facultades, se halla en algún momento restringido por límites —siempre taxativamente determinados por el ordenamiento jurídico o las convenciones privadas—, al desaparecer cualquiera de éstos, el derecho de la propiedad recobra automáticamente el campo perdido.

También se vincula al carácter de absolutez esa tendencia de la propiedad sobre una cosa a ejercer —dándose las condiciones legales— una especie de atracción de la propiedad de las cosas que se le unan natural o artificialmente, lo que se concreta en la institución de la *accesión* *.

PERPETUA

No se extingue por el no ejercicio, ni lleva en sí una causal de extinción, ni puede ser constituida por un plazo determinado. Sí, en cambio, puede pactarse que el adquirente debe retransmitirla al cabo de un tiempo al transmitente.

EXCLUSIVA

No se concibe una simultánea titularidad de dos o más sujetos sobre una misma cosa. Para superar esta imposibilidad se concebirá el condominio *, basado en la coexistencia de varios derechos de propiedad de distintos sujetos, pero sobre partes alícuotas o ideales de una cosa.

DENOMINACION

I. Los romanos, técnica y ritualmente, afirmaban la existencia de un derecho de propiedad con expresiones como "*haec res mea est*" ("esta cosa es mía"), o "*haec res Aulii Agerii est*" ("esta cosa es de Aulio Agerio"). Queda en evidencia la identificación plena, para los romanos, del derecho con la cosa: no se tiene un derecho de propiedad sobre una cosa, se tiene una cosa. También en la época clásica no hablaban de la transferencia de la propiedad, sino de una *translatio rei* (transferencia de la cosa).

II. Por lo demás, sólo en el siglo I a.C. empezará a identificarse el derecho de propiedad con una palabra, hasta ese momento de amplio y genérico significado: *dominium*, proveniente de *dominus*, el señor, el dueño de la *domus* (la casa, el ámbito donde se vive).

Hasta entonces el derecho de propiedad estaba comprendido en la denominación de *mancipium* * con que se venía designando de antiguo el poder unitario, indiscriminado y omnicomprensivo del *paterfamilias* sobre la totalidad de elementos humanos y materiales que integraban la familia.

III. Sólo en la época posclásica se empezó a designarlo con el vocablo *proprietas*, que en un primer momento había servido para caracterizar la íntima —*proprius*: más cercano— o nuda propiedad frente al usufructo.

HISTORIA DEL DERECHO DE PROPIEDAD

La existencia y modalidades de la propiedad en los tiempos arcaicos son difíciles de precisar. En primer lugar, por las escasísimas referencias que nos han llegado; en segundo, porque lo que nuestra mente, analítica y sistematizadora, discrimina como derecho de propiedad, aparece en las vivencias de las sociedades antiguas confundido con lo que para nosotros son otros poderes, atribuciones o derechos: soberanía política, poder correccional, autoridad paterna, gerencia de intereses comunes, etcétera.

De los pocos indicios, puestos en correlación con datos de otras comunidades primitivas, puede aventurarse el siguiente hipotético cuadro de evolución de la propiedad romana.

I. En la etapa precívica —la del ordenamiento gentilicio— parece haber habido 1) un régimen colectivo de apropiación y disfrute de la tierra (o más bien un ejercicio de poder soberano sobre ella); 2) una titularidad familiar a) sobre elementos de producción (esclavos y bestias de tracción), b) sobre los rebaños y lo cosechado por el grupo; 3) una asignación —sin re-

levancia jurídica— a cada individuo de los bienes de uso individual (vestimenta y utensilios).

A nuestro entender, pues, no hay todavía propiedad privada individual: si bien el *paterfamilias* tiene involucrado en su *mancipium* un irrestricto poder de disposición de lo enumerado en 2), lo hace como jefe del grupo y no como titular de una asignación de bienes que, en realidad, la comunidad siente y reconoce para el grupo familiar.

En una economía de autoabastecimiento los intercambios de grupo a grupo son escasísimos; los que podían tener alguna importancia eran los que hemos llamado medios de producción, que serán las primeras *res mancipi*, por destacarse sobre la disposición y manejo de ellas el poder (*mancipium* *) del *paterfamilias*.

II. La primera referencia de propiedad privada en Roma nos la da la tradición que atribuye a Rómulo el haber distribuido entre los *patres* lotes de una media hectárea (*heredium*), que debieron de haber constituido un pequeño huerto rodeando la casa familiar y que fueron transmisibles a los herederos. Aunque creemos que esta noticia fue una anticipación de lo que realmente debe de haber tenido lugar cuando los reyes etruscos, en el siglo VI a.C., asignaron tierras conquistadas, de todos modos, lo exiguo del terreno nos probaría que la actividad pastoril en tierras de la comunidad era la mayor fuente económica para la familia.

En el suelo romano de los primeros tiempos deben de haber coexistido, pues, "propiedad" comunitaria abierta a los ganados de todos y la "propiedad" privada de cada grupo familiar.

III. Cuando la *gens* *, en virtud de los procesos federativos que llevaron a la ciudad estado, fue perdiendo su carácter de unidad política autónoma, su señorío territorial se fue diluyendo en la soberanía que titularizaba la *civitas* y el dominio que sobre las tierras, antes de pastoreo comunitario, fueron desgajando las familias agnáticas *.

Ahora bien, aquel dominio familiar del suelo era más bien un perpetuo derecho de usufructo para la familia, concebida como una unidad integrada también por todas las generaciones

de antepasados y por la posteridad. El jefe de familia aparecía como el gerente de ese usufructo, por cierto, inalienable.

Pero, en tanto en los otros pueblos la tendencia individualista fue llevando a la idea de una copropiedad de los miembros que se tradujo en un cogobierno con el jefe de familia, o, por lo menos, en facultades de control de la actividad de éste, en Roma, en cambio, tal vez circunstancias más duras llevaron a una consolidación del manejo de la cosa familiar en las manos del *pater*, que llegó a extender su autoridad, incluso, más allá de su muerte, al corresponderle designar a su sucesor en la jefatura del grupo.

IV. Su *mancipium*, que, ya vimos, en lo económico era una jefatura gerencial originaria, es decir, sin representación, al sumergirse los grupos en el más complejo contexto de la *civitas*, acentuarse la importancia y frecuencia de las relaciones exteriores al grupo y predominar el manejo de los bienes sobre el mando de las personas, se fue caracterizando como un poder individual de disposición que fue obnubilando el sentimiento de que las cosas estaban afectadas a todo el grupo familiar. Es decir, llegaron a confundirse en el *paterfamilias* el titular de asignación y el de disposición: había nacido la propiedad privada e individual, tal como lo atestigua la ley de las XII tablas.

V. Quedó definido así el *dominium ex iure quiritium* (propiedad quiritaria):

(A) titulariado sólo por un *sui iuris* * romano,

(B) recayendo sobre cualquier mueble, pero sólo sobre inmueble raíz ubicado en territorio de la ciudad estado de Roma (*ager romanus* *) y

(C) sólo transferible, si se trataba de *res Mancipi*, por medio de una *mancipatio* * o una *in iure cessio* *.

En los casos de apropiación en que alguno de estos tres supuestos faltaba se presentaban situaciones que, por conveniencia social o equidad, fueron mereciendo un régimen de tutela que configuró tres tipos de "propiedad":

(A) la peregrina cuando el titular no era ciudadano romano;

(B) la provincial cuando el objeto era un fundo ubicado en el *ager publicus* * (especialmente el territorio provincial), y

(C) la bonitaria cuando una *res Mancipi* simplemente traicionada —sin los actos formales de la *mancipatio* o la *in iure cessio*— u otras *res* en otras hipótesis que le fueron asimiladas, no se consideraban comprendidas en el *dominium* quiritario de una persona, pero sí *in patrimonio* o *in bonis* (entre los bienes).

VI. Pero estos tres tipos de "propiedad" entraron en proceso de equiparación o unificación con la quiritaria.

(A) La constitución de Caracalla * suprimió casi totalmente las diferencias en materia de ciudadanía.

(B) La equiparación d status de las distintas regiones del Imperio borró las diferencias basadas en la ubicación en el *ager romanus* o en el *ager publicus*.

(C) La decadencia de la distinción entre *res Mancipi* y *nec Mancipi* quitó el fundamento que había hecho necesaria la "propiedad" bonitaria.

En la época justiniana hay, pues, una sola clase de propiedad, que conserva lo esencial de la quiritaria, pero que presenta de la provincial la condición de sujetabilidad al impuesto fundario y a límites en el interés público, y de la bonitaria, la ausencia de formas solemnes de transmisión.

CONTENIDO

La doctrina romana no definió la propiedad ni su contenido. Sólo los glosadores medievales lo intentaron; su más corriente formulación es aquella de *ius utendi et abutendi re sua* (derecho de usar y disponer plenamente de la cosa propia) a la que se le suele añadir, pleonásticamente, *ius fruendi* (derecho de gozar).

Los caracteres de absoluta y elástica que definen a la propiedad hacen que resulte más práctico determinar negativamente el contenido de aquella a través de los límites que el ordenamiento legal fue imponiendo a la plenísima facultad de aprovechamiento y disposición de la cosa.

Se pasó de un régimen de absoluta libertad, de una excluyente soberanía del *paterfamilias* —sobre un fundo cerrado

(*ager limitatus*) con límites sagrados y con un espacio libre alrededor para que la necesidad del tránsito no impusiera servidumbres legales de paso—, a otro en que se regulan limitaciones en razón del interés colectivo y de los vecinos.

Se distinguen así limitaciones de derecho público y de derecho privado.

No se considera limitación, en estricto sentido, la eventual coexistencia, con la propiedad de los llamados derechos reales sobre cosa ajena.

LIMITACIONES DE DERECHO PUBLICO

I. En la ley de las XII tablas y en estatutos de municipios se encuentra la prohibición de enterrar o cremar cadáveres en fincas urbanas.

II. El pasaje forzoso, sólo impuesto: (A) provisionalmente mientras dure la intransitabilidad de un camino público; (B) permanentemente en favor de quien tiene el *ius sepulchri* para allegarse hasta el lugar *religiosus* *.

III. Los fundos colindantes con ríos navegables deben soportar el uso de la ribera para las maniobras necesarias a la navegación.

IV. En el período clásico ya son numerosas las reglamentaciones en cuanto a la altura, distancia y estética de las construcciones edilicias.

V. Desde el 382 d.C. se concede el excavar en busca de minerales en fundos ajenos, siempre que se pague un décimo de lo logrado al propietario y otro al fisco.

VI. Desde el 292 d.C., los fundos objetos del *dominium ex iure quiritium* fueron sometidos a impuesto territorial y perdieron así esa condición de inmunidad que distinguía a ese *dominium* de los otros tres tipos de propiedad.

VII. Si bien la expropiación por causa de utilidad pública no es tratada ni aludida en las fuentes clásicas, algunas disposiciones, a partir de Teodosio II (muerto en el 450 d.C.), que facultaban a funcionarios a demoler edificios con indemnización

a los propietarios, parecieran confirmar la existencia de tal institución.

LIMITACIONES DE DERECHO PRIVADO

I. Desde las XII tablas se podrá exigir al vecino el corte hasta 15 pies de altura de las ramas de un árbol extendido más allá del límite.

II. También desde esa ley se tenía el derecho de pasar en días alternos al fundo contiguo a recoger los frutos de las plantas propias.

III. En casos de un fundo incomunicado como resultado de una acción divisoria, el juez podía imponer en la *adiudicatio* una servidumbre de paso.

En el derecho justiniano se extiende esa institución a otros supuestos de incomunicación.

IV. Sobre la base del principio de que las aguas deben fluir en forma natural, se concedió una *actio aquae pluviae arcendae* contra el propietario que construyendo o destruyendo obras o defensas alterase ese fluir en detrimento del vecino.

V. Algunas disposiciones en el derecho justiniano que ponían otras restricciones a la propiedad inmueble por razones de vecindad, han dado pie a que los juristas medievales elaboraran la doctrina de la prohibición de los actos *ad aemulationem*, hechos por el propietario no para su beneficio, sino con el fin de dañar al vecino. De todos modos, en los textos clásicos no se encuentra nada en tal sentido y es cuestión controvertida si un principio general con esa finalidad fue introducido luego por el cristianismo.

CONDOMINIO

Es la coexistencia de dos o más titulares del derecho de propiedad sobre una cosa.

I. Primitivamente, la única forma de condominio era el *consortium* * *creto non cito*, que se constituía automáticamente

entre los descendientes sometidos a la inmediata patria potestad del *pater*, cuando éste moría. A cada miembro correspondía la plenitud del *dominium*, cada uno cumplía válidas manumisiones del esclavo en común o *mancipationes** de las cosas en común. Un *ius prohibendi* (derecho de veto) completaba la semejanza del ejercicio de ese condominio con la colegialidad* de la magistratura.

II. Surgió luego un nuevo tipo de condominio basado en la idea de que el derecho de cada uno a la totalidad de la cosa está limitado por el concurrente derecho de los otros a una porción o cuota ideal, que acrece automáticamente ante el abandono que de las cuotas ideales realicen los condóminos; por ejemplo, si alguno manumite un esclavo común, éste sigue en propiedad de los otros condóminos, ahora con sus cuotas acrecentadas en proporción.

III. Cada condómino ejercita sus facultades por su cuota: transfiere, da en usufructo o en prenda, reivindica, adquiere los frutos, etcétera.

Tratándose de actos comunes de utilización de la cosa, cada condómino los cumple sin previo consentimiento de los otros, el que si es, en cambio, necesario para actos que signifiquen innovación: de no otorgarse dicho consentimiento, subsiste, para el condómino no consentidor, el *ius prohibendi* en la forma de un derecho a obtener un retorno a la situación anterior al acto no consentido.

En el derecho justiniano se tendió, en cambio, a: 1) considerar al *ius prohibendi* sólo como defensa previa a la concreción del acto no querido y 2) a organizar un régimen de decisión por mayoría de cuotas.

IV. Siempre a salvo, claro está, el derecho a poner fin al condominio, concebido, por lo demás, como temporal, por lo que no se admitía un pacto de perpetuidad. Lo más común era la *actio communi dividundo* para un condominio no resultante de una herencia.

En esa acción la *condemnatio pecuniaria* podía servir no sólo para compensar —si las adjudicaciones de las partes no podían corresponder exactamente a las cuotas—, sino también

para reglar todos los créditos surgidos entre los titulares del condominio con motivo de éste.

MODOS DE ADQUISICION DE LA PROPIEDAD

Son los hechos jurídicos que establecen la adquisición por parte de una persona determinada del derecho de propiedad sobre una cosa.

Las fuentes romanas distinguen entre modos de adquisición del *ius naturale* o *ius gentium* —comunes a todos los hombres, porque tenían su base en la *naturalis ratio*— y modos propios del *ius civile* —reservados exclusivamente para los ciudadanos romanos, aunque la *mancipatio* se le permitiera a los no ciudadanos dotados de *ius commercii*.

Otra clasificación moderna, aunque alejada del pensamiento romano, es, sin embargo, preferible para orientarse en esta materia que los romanos no sistematizaron completamente: la de modos derivativos y modos originarios, según que el derecho se origine para su titular, con relación jurídica o sin ella, de éste con un precedente titular.

MODOS DE ADQUISICION	
	Ius gentium y naturale Ius civile
Originarios	Ocupación
	Accesión
	Especificación
	Confusio-commixtio
	Adquisición de los frutos
Derivativos	Usucapio
	Mancipatio
	In iure cessio
	Adiudicatio
	Litis aestimatio

MODOS ORIGINARIOS

Ocupación. — Consiste en la toma de posesión de una cosa que no tiene dueño (*res nullius*), con la voluntad de tenerla como propia.

I. Objeto de ocupación: son la isla aflorada en el mar; en un río —si los fundos ribereños son *limitati**—; las cosas encontradas en el litoral marítimo; los animales que viven en estado natural, es decir los salvajes, en contraposición a los domésticos; las *res hostiles*, es decir las cosas pertenecientes a los enemigos, con exclusión del botín bélico y del suelo.

- * Las cosas abandonadas por sus dueños con signos evidentes de no quererlas tener más como propias resultan, según criterio de los sabinianos, que hace suyo Justiniano, *res nullius* desde el instante del abandono y su adquisición se opera por ocupación. Según los proculeyanos, la pérdida de la propiedad sólo tiene lugar en el momento de su apoderamiento por otra persona. Se ha llegado a establecer en este caso una analogía con la llamada *traditio in incertam personam* (tradición a persona indeterminada): tal la que tiene lugar cuando se arrojan monedas a la multitud.
- * No parece haber existido derechos exclusivos de caza; aun con prohibición del dueño del fundo y al margen de indemnizaciones o sanciones, la adquisición del animal tenía lugar, según los encontrados criterios, sea por haberle solamente imposibilitado la fuga, sea por haberlo capturado efectivamente.
- * Los animales salvajes si, domesticados, se han escapado pueden ser objeto de ocupación si no tienen o han perdido la *consuetudo reverendi* (el hábito de retornar).

II. Del régimen general de la *occupatio* se destaca, a partir de Adriano, una de sus especies: la adquisición del tesoro. Según se define en el "Digesto", "tesoro es cualquier antiguo depósito de dinero [o cosas preciosas] del que no queda recuerdo, de tal manera que ya no tiene dueño". Si era encontrado 1) en fundo propio o, por azar, en lugar sacro o religioso, correspondía plenamente al descubridor; 2) si también por azar, en fundo ajeno o público, el tesoro correspondía por mitades al descubridor y al dueño del fundo o al fisco, respectivamente; 3) si era encontrado en fundo ajeno como resultado de una búsqueda (*data opera*), no le correspondía nada al descubridor y si la totalidad al dueño del fundo.

Accesión. — Bajo ese nombre se agrupan tradicionalmente varias hipótesis de unión entre cosas de distintos dueños, de las que una se considera principal y atrae para su dueño la propiedad de la otra u otras, consideradas accesorias.

La determinación del carácter de principal generalmente se basa en la función económico-social del todo resultante.

I. Un primer grupo de hipótesis lo constituyen las accesiones de inmueble a inmueble, debidas a los incrementos fluviales.

- * *Aluvio*, cuando partículas de tierra llevadas por la corriente incrementan paulatina e insensiblemente un fundo ribereño.
- * *Acusio*, cuando una porción de tierra impulsada por la corriente se adhiere en forma estable a un fundo ribereño.
- * En estos dos casos hay una adquisición irrevocable.
- * *Insula in flumine nata*, cuando aflora una porción de tierra en medio del río.
- * *Alveus derelictus*, cuando al abandonar su curso el río, queda su lecho entera y establemente abandonado por la corriente.
- * En estos dos casos hay también una adquisición irrevocable a favor del propietario del fundo ribereño, dentro de la línea media del río y las rectas perpendiculares a ésta, que sean trazadas desde donde los confines del fundo tocan la ribera.

Todas estas accesiones tienen lugar siempre que los fundos no sean *limitati*, es decir, rodeados de ese límite de cinco pies que era característico del fundo objeto del *dominium ex iure quiritium*. En este otro supuesto no juega la accesión sino la adquisición por ocupación.

II. Un segundo grupo de hipótesis se refiere a la accesión de muebles a inmuebles.

- * *Plantatio y seminatio*: hay adquisición irrevocable de las semillas germinadas y plantas arraigadas.
- * *Inaedificatio*: se produce la adquisición para el dueño del fundo de la propiedad de lo edificado en él; pero, en razón del interés público, la propiedad de los materiales de construcción era preservada, desde la ley de las XII tablas, al dueño de ellos. Este no podía, sin embargo, intentar la *actio ad exhibendum* (acción para que se presente, se exhiba [ante el tribunal la cosa mueble para ser identificada a los efectos de una posterior reclamación de ella o a causa de ella]) y la reivindicación hasta que la destrucción del edificio pusiera término a la accesión. Pero, tratándose de materiales objeto de un *furtum**, al

propietario se le otorgaba una acción penal que imponía al propietario del fundo una multa del doble del valor de los materiales. Aun así, le era posible reivindicar los materiales una vez desaparecido el presupuesto material de la accesión. Justiniano, empero, estableció la disyuntiva: o esta acción —que pasa a ser, entonces, indemnizadora— o la *reivindicatio*.

- Para el supuesto contrario —una persona construye con materiales propios en un fundo ajeno— hay la siguiente casuística: (A) nunca tiene derecho a demoler para retirar sus materiales; (B) si es de buena fe y conserva la posesión de lo edificado, puede interponer la *exceptio doli* ante la *reivindicatio* del propietario del fundo y conseguir así el resarcimiento de las *impensae* necesarias y útiles; (C) aun siendo de buena fe, no tiene acción si ha perdido la posesión; (D) si es de mala fe y conserva la posesión, podría tal vez retenerla hasta el resarcimiento de los gastos necesarios, pero no podía nunca reivindicar sus materiales; (E) Justiniano, en cambio, reconocerá —aun al de mala fe— el *ius tollendi* (derecho de alzar, sacar) con respecto a los materiales no imprescindibles a lo edificado, y aun reivindicar, una vez terminada la existencia del edificio.

III. Un último grupo de hipótesis concierne a la accesión de muebles a muebles.

- *Plumbatura. Ferruminatio*: Según que la adhesión de cosas metálicas ocurra con intermediación de otro metal o sin ella —generalmente plomo—, la adquisición se considera revocable o irrevocable respectivamente.
- *Scriptura, tinctura*: Los materiales de escribir y de teñir acceden al material escrito o teñido.
- *Pictura*: Por el contrario, se abrió camino la opinión —aceptada por Justiniano— de que la tela o tabla pintada accede a la pintura.
- *Textura*: Se considera revocable la adquisición de los hilos por parte del dueño del cánamazo o de tela bordada.

IV. En cuanto al eventual derecho del propietario de la cosa accesoria a ser indemnizado por la pérdida sufrida, hay que discriminar la revocabilidad o no de la adquisición sobre la base de la posibilidad material o legal de terminarse el estado de accesión.

- Si era revocable se ejercía una *actio ad exhibendum* para obtener la separación de la cosa accedida y proceder así a su reivindicación. Así, en los casos de *textura* y *plumbatura*. No en el caso de *in edificatio*, en que tal accionar era suspendido mientras durara el edificio.
- Si era irrevocable, habríanse otorgado en la época justinianeas acciones *in factum* para obtener el resarcimiento. En el derecho clásico se le concedía al dueño de la cosa accesoria que se hallase en posesión

de la principal —por ejemplo, el tintorero, el constructor de buena fe de un edificio con materiales propios en fundo ajeno— una *exceptio doli* ante la reivindicación planteada por el dueño de la última. Con ello podía conseguir el total valor estimado de la cosa accesoria.

Especificación. — Para que pueda plantearse el problema de si existe o no especificación —adquisición por transformación en una especie nueva— se requiere:

- 1) transformación en una especie nueva,
- 2) efectuada por quien no es el dueño de la especie original,
- 3) sin consentimiento del dueño y
- 4) con el ánimo de tenerla para sí.

I. Los sabinianos entendían que la especie nueva seguía perteneciendo al dueño de la materia original: no hay, pues, especificación.

Los proculeyanos, que el autor de la nueva especie la ha adquirido: hay especificación.

II. Justiniano distingue: según no sea o sea posible volver las cosas a su estado primitivo habrá especificación o no, respectivamente.

En el derecho clásico no se exigía la buena fe —en este caso, la ignorancia en cuanto a la propiedad de la cosa— del especificador, pero Justiniano la hace condición necesaria para la adquisición. También establece que habrá especificación en todos los casos en que el especificador —de buena fe, claro está— haya utilizado parte de materia suya.

Confusio y commixtio. — La primera es una mezcla de cosas líquidas o en fusión; la segunda, de cosas sólidas. En ambos casos, siempre que no pueda hablarse de cosa principal y accesoria ni de una especie nueva resultante de la mezcla.

Los propietarios de las cosas mezcladas, según que fuera impracticable o no la separación, eran considerados condóminos en forma proporcional o podían reivindicarlas.

No había, pues, adquisición en la mezcla, a no ser en el caso de monedas: quien recibía, a cualquier título, monedas y las mezclaba con las suyas, las adquiría en virtud de la *commixtio*. Quedaba, por cierto, obligado ante los primitivos dueños, que no podían reivindicar pero sí intentar las acciones persona-

les correspondientes.

Adquisición de los frutos naturales. — El problema se plantea a partir de la separación de la cosa fructífera; sólo entonces tienen una individualidad propia, pues estando pendientes forman parte de la cosa.

Por regla general son adquiridos por el dueño de la cosa fructífera, pero a veces por terceros que tienen sobre ella un derecho real, o personal, o la poseen de buena fe.

Por la simple separación (*separatio*) los adquieren los enfiteutas y los poseedores de buena fe, si bien éstos, en el derecho justinianeo, están obligados a restituir al propietario reivindicante los no consumidos.

Por percepción (*perceptio*) adquieren los usufructuarios y los arrendatarios. En este último caso se consideraba una especie de *traditio*, en tanto acaecía la percepción por voluntad del dueño; y estaríamos, entonces, ante un modo de adquirir derivativo.

Usucapio. — Es el modo de adquisición mediante la posesión —*usus**— por un cierto tiempo y con concurso de otros requisitos.

I. Ya la ley de las XII tablas regulaba: *usus auctoritas fundi biennium, ceterarum rerum annus esto* (la posesión y la *auctoritas* sea de dos años para el fundo y de un año para las restantes cosas). Quedaba así establecida, correlativa y complementariamente, que la garantía de evicción (*auctoritas**) debida por el que daba en una *mancipatio* debía durar lo necesario hasta que en virtud de la *usucapio* quedara confirmado el derecho de propiedad del que había recibido la cosa en esa *mancipatio*.

La *usucapio* venía así a superar toda duda en cuanto a la pertenencia de una cosa y evitaba la necesidad de remontarse en el tiempo para ir justificando la legitimidad de los títulos de los distintos propietarios sucesivos. Es decir, la *usucapio* obviaba lo que los comentaristas llamaron la *probatio diabólica*, por la dificultad, rayana en la imposibilidad, de probar los orígenes de un determinado dominio.

II. La adquisición por *usucapio* era sólo posible —como ins-

titución que era del *ius civile*— a propósito de cosas susceptibles del *dominium ex iure quiritium*—no de los fundos provinciales, por ejemplo— y de sujetos que fueran ciudadanos romanos.

Por ello las XII tablas parecen haber establecido que, como los extranjeros no podían usucapir*, quienes les habían transferido cosas estaban obligados a prestarle indefinidamente la garantía por evicción (*adversus hostem aeterna auctoritas*).

III. El derecho arcaico y preclásico no imponía para la *usucapio* otra condición que la de no recaer sobre cosas furtivas—objeto de un *furtum**— o poseídas con un acto inicial de violencia (*res vi possessae*).

Pero con el tiempo, de acuerdo con las crecientes exigencias de equidad, eticidad y observancia de la buena fe, se fueron añadiendo otras condiciones hasta ser, al fin de la época clásica, cinco, que los comentaristas medievales resumían en un verso hexámetro:

res habilis, titulus fides, possessio, tempus

(A) *Res habilis ad usucapionem.* — La cosa debía ser susceptible de *usucapio*. No lo eran las *res extra commercium*, las cosas furtivas, las *res vi possessae*, los regalos hechos en provincia al promagistrado, las cosas del fisco y personales del emperador, los fundos de la dote o los rústicos del pupilo, etcétera.

(B) *Titulus.* — Es la *iusta causa usucapionis*, hipótesis que habría justificado la inmediata adquisición de la cosa si no hubiera habido algún vicio o defecto en el acto de transmisión. Por ejemplo, el *titulus pro emptore*, *titulus pro donato*, *titulus pro dote*, *titulus pro soluto*, cuando el usucapiente posea una cosa en base, respectivamente, a compraventa, donación, constitución de dote o cumplimiento de una prestación, sin haber devenido propietario con la *traditio*, sea por tratarse de *res Mancipi*, sea por haberla efectuado un no dueño (*a non domino*); el *titulus pro legato* cuando se recibió legado *per vindicationem** hecho *a non domino*; el *titulus pro derelicto* cuando la cosa derelicta* no fue adquirida por ocupación, en razón de haber sido abandonada por un poseedor *non dominus*; etcétera.

En el derecho clásico era controvertida la admisibilidad de un *titulus putativus*, es decir, existente sólo en el pensamiento —*putare* (pensar)— del alienante o adquirente, pero no en la realidad de las cosas: por ejemplo, una tradición hecha en base a un contrato de compraventa inexistente.

Pero Justiniano lo admitió como posibilitador de la *usucapio* siempre que el error del usucapiente fuera un *error tolerabilis*.

(C) *Fides*. — La *bona fides* aludía a la convicción del usucapiente de que su posesión no era lesiva del derecho de otra persona. Esta convicción era exigida, con respecto al momento inicial de la posesión: *mala fides superveniens non nocet* (la mala fe sobreviniente no perjudica [a la posesión]).

(D) *Possessio*. — Naturalmente la posesión era *ad usucapionem* * —es decir *civilis* o *bonae fidei*—. Una interrupción, aunque momentánea, requería recomenzar la posesión.

(E) *Tempus*. — Antes de su fusión con la *praescriptio longi temporis*, el período de posesión exigido para la *usucapio* seguía siendo el de la ley de las XII tablas: dos años para los inmuebles y uno para las cosas muebles, pero para la *usucapio hereditatis* * se requería tan sólo un año —aunque la herencia comprendiera inmuebles—, toda vez que se consideraba que recaía no sobre las cosas que la constituían, sino sobre la *hereditas* * como conjunto.

FUSIÓN DE LA USUCAPIO CON LA PRAESCRIPTIO. — La *praescriptio longi temporis* era un modo típico de mantener la *possessio* o *ususfructus* de los fundos provinciales. En realidad, era una *exceptio*, de la época de los Severos, que se oponía a una *reivindicatio utilis* —*utilis* * porque no reivindica un *dominium ex iure quiritium*, sino una propiedad provincial—. Podía invocarse cuando se había poseído por más de diez o veinte años según el titular fuera de la misma *civitas* en que estaba el fundo provincial o no.

La *praescriptio l. t.* no era en realidad un modo o título de adquisición de esa propiedad, sino un medio procesal apto para tutelar la disposición del fundo provincial.

En el derecho justiniano, desvanecidas las diferencias entre los distintos tipos de propiedad, se funden la *usucapio* con la *praescriptio l. t.* La palabra *usucapio* ya había comenzado a usarse con referencia a la adquisición de las cosas muebles, para la que se requirió un plazo de posesión de tres años. La *praescriptio l. t.* designó entonces al régimen de adquisición de cualquier inmueble y con el mismo plazo de 10 y 20 años de la antigua *praescriptio l. t.* de los fundos provinciales.

Por cierto, los cinco presupuestos —*res habilis, titulus, fides, possessio, tempus*— se exigen para ambas instituciones.

PRÆSCRIPTIO LONGISSIMI TEMPORIS. — Constantino había establecido contra la reivindicación una excepción fundada en la posesión durante cuarenta años, aun sin *iusta causa* y *bona fides*. Sobre esa base y la prescripción extintiva de acciones establecida por Teodosio II en el 424 d.C., Justiniano introduce la *praescriptio longissimi temporis* por la que el plazo de esta prescripción extraordinaria se lleva a 30 años y 40 si se va invocar en perjuicio del estado, de la Iglesia o de las fundaciones pías. No se exige la *iusta causa* o *titulus*, pero sí la *bona fides*.

MODOS DERIVATIVOS

Mancipatio. — La *mancipatio* es el negocio jurídico más característico y versátil del Derecho Romano. Casi seguramente fue en sus orígenes una compraventa real, es decir, un negocio que se perfeccionaba con la formal dación del precio por una parte y de la cosa por la otra parte.

- Tal se deduce de su estructura en los tiempos históricos: ante cinco testigos y un *libripens* (sostenedor de una balanza), la parte activa toca con un trozo de cobre la balanza mientras pronuncia palabras solemnes que constituyen el *ius* * calificante del acto.
- Evidentemente, el trozo de cobre ha quedado como estilizado símbolo de la concreta cantidad de metal que debía ser efectivamente pesada —en los tiempos en que no existía la moneda de peso ya determinado— previamente a su entrega al otro participante, pasivo y consentidor con su silencio.

I. La jurisprudencia pontificial extendió el uso de aquella primitiva venta real como encuadre para actos jurídicos relati-

vos a antiguas y sobrevivientes instituciones. Y ello fue posible por dos razones fundamentales. Primeramente, porque en virtud de que la *mancipatio* era antonomásica y esencialmente un acto de constitución o transferencia del *mancipium**, fue posible su aplicación a todos los casos en los que se espectraló o desplegó aquel poder genérico y unitario. En segundo término, por el principio —consagrado, por lo demás, en la ley de las XII tablas— de que el enunciado de las palabras pronunciadas en el acto —*nuncupatio*, palabra derivada casi con seguridad de *nomen capere* (aprehender, dominar la palabra)— tenía el poder —¿mágico, ritual o jurídico?— de normar el acto, aunque éste no era pasible de plazos ni condiciones.

II. La *mancipatio*, pues, de negocio jurídico con concreta causa se convirtió en negocio abstracto —*imaginaria venditio*— que daba los marcos formales para solemnizar actos jurídicos de distintos contenidos o finalidades: transferencia del dominio quirritario; transferencia fiduciaria de la familia (*mancipatio familiae*), constitución de *mancipium* —sea real o ficticia, con el objeto de emancipar* o dar en adopción*— sobre un *alieni iuris* ajeno a la familia, constitución de *manus* sobre una mujer, *verum*, etcétera.

III. En el caso de la transferencia del *dominium ex iure quiritium* nacía simultáneamente a cargo del alienante la obligación de la *auctoritas*, garantía al adquirente de intervenir y responsabilizarse si un tercero reivindicase la cosa. En ese supuesto, si rehusaba su intervención en el juicio o si no demostraba en éste haber sido al momento de la *mancipatio* el legítimo titular de la cosa y el adquirente la perdía, le correspondía a este último la *actio auctoritatis in duplum*, es decir, por el doble del precio pagado.

In iure cessio. — Consistía en una estilizada ficción de reivindicación. El propietario y la persona a quien se deseaba transferirle el *dominium* se presentaban ante el magistrado —*in iure*—. Entonces, el que pretendía adquirir, reivindicaba falsa-

mente la cosa; el alienante, en vez de oponer su *contravindicatio*, callaba —tal vez echaba un paso atrás (*cedere*)—, y con esto otorgaba la pretensión invocada. El pretor consideraba entonces establecida la titularidad del reivindicante y efectuaba su *addictio* (adjudicación).

También, como la *mancipatio*, este procedimiento se usó ampliamente para la constitución de otros derechos comprendidos en el genérico y unitario poder del *paterfamilias*, el *mancipium*.

Tradición. — Es la puesta a disposición de la cosa por el alienante al adquirente. Para que esa transferencia material implicara transferencia del derecho de dominio se requería:

- a) que la cosa fuera *res nec mancipi*;
- b) que estuviese en el *dominium ex iure quiritium* del tradente;
- c) que éste quisiera efectivamente transferirla a la contraparte y ésta aceptarla;
- d) que existiese una *iusta causa traditionis*, es decir, una situación o relación jurídica que, de acuerdo con el derecho objetivo, fuera apta para justificar la transferencia del dominio.

Las *iustae causae traditionis* podían ser la transferencia como cumplimiento de la prestación del deudor, o con el fin de celebrar un mutuo, o de establecer una dote, etcétera. No eran *iustae causae* las que se hacían en función de actos prohibidos —donación a un cónyuge— o de negocios jurídicos, que, como el depósito o el comodato, requieren la entrega de la simple tenencia.

Con el tiempo, aquel requisito de la efectiva transferencia de la cosa fue sufriendo atenuaciones de distinto orden que subrayaban, en cambio, la importancia creciente dada al *animus tradendi* (intención de hacer tradición).

Distingamos. (A) Efectiva transferencia: 1) si mueble, entrega en la mano; 2) si inmueble, entrada del adquirente. (B) Atenuación de la exigencia; 1) si mueble, la tradición simbólica

de las mercaderías de un depósito o almacén mediante la entrega de las llaves; 2) si inmueble, la llamada *traditio longa manu* —sin necesidad de llegar a penetrar en él, simplemente señalarlo a distancia—. (C) Sin ninguna exteriorización material: la *traditio brevi manu*, consistente en un íntimo cambio de *ánimus* en las partes cuando el que tenía una mera tenencia de la cosa pasaba, de acuerdo con el propietario, a poseerla como propia; el *constitutum possessorium*, consistente en un cambio de *ánimus* inverso al anterior: quien poseía como propietario, en virtud de un negocio jurídico transfería el dominio, pero continuaba con la tenencia de la cosa como usufructuario, locatario, etcétera.

Como se ve, en los dos últimos tipos de tradición no hay absolutamente ninguna exteriorización material —ni siquiera ficticia o simbólica— de la transferencia de la cosa.

Adjudicatio. — Es el pronunciamiento del juez —facultado por la parte de la fórmula* llamada precisamente *adiudicatio*— en juicios divisorios en el que se atribuye a primitivos condóminos la propiedad exclusiva sobre las distintas porciones en que se ha dividido la cosa común.

Litis aestimatio. — Tiene lugar como adquisición de la cosa litigiosa: a favor del poseedor o tenedor que, habiendo perdido el juicio, en vez de restituir la cosa, prefiere pagar la condena pecuniaria según la *litis aestimatio* y quedarse con la cosa.

DEFENSA PROCESAL DE LA PROPIEDAD

Las instituciones de defensa de la propiedad eran:

(A) contra la violación total del derecho, la reivindicación y la *actio Publiciana*;

(B) contra la violación parcial del derecho, la *actio negatoria*;

(C) contra amenazas a la integridad material de la cosa, la *actio finium regundorum*, la *operis novi nuntiatio*, la *cautio damni infecti*, la *actio aquae pluviae arcendae* y el *interdictum quod vi aut clam*.

REIVINDICACION

Es la acción del que pretende ser propietario *ex iure quiritium* y que no se halla en posesión de la cosa contra el poseedor, para lograr la restitución de ella o el pago de su valor.

- Al final del período clásico se permitió accionar contra el tenedor a nombre de otro —comodatario, depositario, etcétera—. Justiniano extendió la posibilidad de ser demandado tanto al que dejó de poseer la cosa —cediéndola a otro, abandonándola, destruyéndola, etcétera— cuanto al que se dejó llevar al juicio sin haberla nunca poseído —*fictus possessor*—, engañando así al actor en cuanto a la identidad del poseedor y permitiendo eventualmente que éste pudiera usucapir.
- El condómino podía reivindicar sólo por su cuota parte.

PROCEDIMIENTO

En los primeros tiempos la reivindicación se tramitaba con la *legis actio sacramento in rem*, en la que ambas partes debían afirmar —en la etapa *in iure*— y probar —en la *apud iudicem*— su derecho de propiedad.

En el procedimiento *per sponsionem*, el actor se hacía prometer, por una *sponsio* del demandado, que éste le pagaría una suma si el actor era reconocido como propietario quiritario de la cosa.

Pero lo corriente a partir del período clásico fue la *formula petitoria vel arbitraria*, en la que también sólo al actor incumbe la prueba de su derecho de propiedad: si el demandado tiene la

possessio ad interdicta, queda con la cosa si el actor no prueba su derecho. Si, por el contrario, lo prueba, el juez ordena en la cláusula arbitraria devolver la cosa y efectuar ciertas restituciones accesorias. Si el demandado no lo hace, tiene lugar la clásica condena pecuniaria con una estimación por juramento del actor.

- * Tres actitudes podrá tomar el poseedor al ser demandado: 1) abandonar la cosa; 2) negar su cooperación para que se entable la *litis contestatio*: el pretor le ordena —si se trata de un inmueble—, por el interdicto *quem fundum*, transmitir la posesión al actor; o —si de una cosa mueble— soportar que el actor se la lleve sin más; 3) aceptar el juicio y, en tal caso, dar garantías de asegurar el resultado de la condena: si no lo hace, el pretor da la posesión de la cosa al actor que está dispuesto a dar aquellas garantías y que se beneficia al no tener —como poseedor que ha resultado— el cargo de la prueba.

RESTITUCIONES

La cosa reivindicada debía ser restituida con todo cuanto el actor hubiere tenido si le hubiera sido devuelta en el momento de la *litis contestatio*, a saber: (A) la cosa reivindicada y sus accesorios —por ejemplo, el esclavo y los legados que éste hubiera recibido—; (B) los frutos percibidos desde la *litis contestatio* y los que se dejaron de percibir por negligencia; (C) los percibidos antes, de existir todavía; (D) los percibidos o dejados de percibir antes, si se trataba de un poseedor de mala fe; (E) las indemnizaciones por los daños ocurridos desde la *litis contestatio* por el dolo o la culpa de un poseedor de buena fe; (F) las indemnizaciones por daños anteriores debidos a dolo o culpa, aun cuando ésta sea leve, y por daños posteriores, incluso si éstos se debieran a causa fortuita, si se trataba de un poseedor de mala fe.

IMPENSAS

El propietario reivindicante debía, a su vez, resarcir los gastos hechos por el poseedor en razón de la cosa.

(A) Los gastos necesarios —sin los cuales la cosa hubiera perecido o sufrido daños— deben ser reintegrados al poseedor

de buena fe, no al de mala fe. Justiniano asimila a éste con aquél: ambos tendrán un derecho de retención hasta ser satisfechos.

(B) Los gastos útiles —verbigracia, embaldosar un camino— que han producido un mayor valor objetivo de la cosa deben abonarse al poseedor de buena fe en el monto del mayor valor producido.

(C) Los gastos voluptuarios —por ejemplo, haber instalado estatuas— que no han añadido un valor objetivo a la cosa no dan lugar a resarcimiento, pero sí a llevarse las cosas en que se concretaron.

ACCION PUBLICIANA

Es una acción, creada por el pretor Publicius, contemporáneo de Cicerón, a imitación de la reivindicación, que se otorga a quien ha perdido la posesión de una cosa que estaba en tren de usucapir, para que pueda recuperar dicha posesión.

- * Es una acción ficticia: el pretor indica al juez que haga de cuenta de que el plazo de la *usucapio* ha transcurrido y que sólo constate que los otros requisitos —*iusta causa* o *titulus* y *bona fides*— se hayan dado en una posesión, aunque sea instantánea, de la cosa.

La acción Publiciana puede ser ejercitada por (A) el propietario bonitario en razón de haber recibido tradición *ex iusta causa* de una *res Mancipi*; (B) todo poseedor a *non domino* (no de parte del dueño [de la cosa]), pero con *iusta causa* y *bona fides*; (C) el propietario quiritario, que necesitará una prueba más fácil que si intentara una *reivindicatio*.

(A) EL PROPIETARIO BONITARIO

El adquirente, por tradición, de una *res Mancipi*, no había adquirido el dominio quiritario por falta del acto legítimo

SB

504 1

—*mancipatio* o *in iure cessio*—, pero tenía todas las condiciones para usucapir. Su riesgo era perder la posesión antes de cumplido el plazo de la *usucapio*. El pretor le protege el derecho sobre la cosa, que tiene *in bonis* (en su patrimonio), acordándole la acción Publiciana, tanto contra cualquier tercero poseedor de la cosa como contra el mismo propietario quiritarario que, de vuelta, se hubiere posesionado de ella.

- Este último puede invocar contra la Publiciana una *exceptio iusti domini* (excepción de propiedad legítima), pero el actor interpone una *replicatio rei venditae et traditae* (réplica de cosa vendida y tradiconada) eludiendo al dolo implícito en la invocación de propiedad por parte de quien había vendido y entregado la cosa.

(B) EL POSEEDOR DE BUENA FE A NON DOMINO

La acción Publiciana fue extendida luego para todo adquirente *ex iusta causa* que por falta de título del enajenante no hubiera alcanzado inmediatamente la condición de *dominus*. También a los casos en que el pretor concedía la posesión de cosas singulares o de patrimonios —*bonorum possessio**, *bonorum emptio*, etcétera.

- Si ese poseedor ejerce la Publiciana contra el propietario quiritarario, éste interpone la *exceptio iusti domini*, que no podrá ser replicada con la *rei venditae et traditae*; por tanto, el propietario retiene la cosa.
- Si la ejerce contra un propietario bonitario será vencido por una excepción de adquisición *a domino* (del dueño) que aquél interponga.
- Si la ejerce contra otro de su misma condición, triunfa el poseedor actual de la cosa si la tradición les fue hecha a ambos por distintos no dueños. Si el tradente no dueño fue el mismo, triunfa el que primero fue puesto en posesión.

(C) EL PROPIETARIO QUIRITARIO

Este puede utilizar la acción Publiciana con la ventaja de que la prueba a rendir es menos exigente que la necesaria para la *reivindicatio*.

ACCION NEGATORIA

Contra menores o limitadas violaciones de la propiedad correspondía la acción *negatoria*, con la que el propietario afir-

maba la inexistencia de un derecho real ajeno sobre la cosa de su propiedad. En el juicio él debía probar simplemente su derecho de propiedad; a la otra parte le correspondía probar la existencia de un derecho real limitativo de aquel derecho de propiedad.

ACTIO FINIUM REGUNDORUM

Tenía por objeto determinar los confines confusos o controvertidos entre fundos rústicos.

OPERIS NOVI NUNTIATIO

Antiguo medio jurídico por medio del cual, quien pretendía tener —por razones de tutela de leyes edilicias, o de defensa de una servidumbre urbana, o de garantía respecto a un eventual daño— un *ius prohibendi* sobre nuevas obras o demoliciones, efectuaba frente a las obras una ritual intimación para que se detuvieran.

CAUTIO DAMNI INFECTI

Medio jurídico encaminado a garantizar contra un daño temido en base a un estado amenazante de las construcciones hechas o en ejecución.

El pretor, previa una *causae cognitio* (examen de la causa), imponía al dueño de la construcción amenazante una estipulación pretoriana por la que se lo obligaba a resarcir el daño eventual. Si se resistía a adquirir esa obligación, el pretor podía darle al reclamante una *missio in possessionem* de la construcción. Justiniano dispuso que en lugar de esa posesión se diera la propiedad.

ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE

Medio jurídico para asegurar el normal régimen de despla-

82

zamiento del agua pluvial cuando el fluir de la misma hubiera sido alterado por una obra realizada en un fundo vecino en detrimento del propio.

INTERDICTUM QUOD VI AUT CLAM

Concedido para obtener una vuelta al primitivo estado de cosas cuando alguien, dentro del año, había efectuado obras en fundo propio o ajeno, contra la prohibición —vi— o a escondidas —clam— de quien —poseyendo en derecho real o personal sobre ese fundo o el vecino— podía verse o creerse afectado por algún daño o peligro.

LA POSESION

En términos generales, se entiende, hoy en día, por posesión, el señorío o disposición de hecho sobre una cosa con la pretensión de tenerla como propia. Se distingue tanto de la propiedad —que es un señorío jurídico absoluto, es decir, sostenido por el ordenamiento jurídico y oponible *erga omnes*— cuanto de la tenencia, concebida como una mera disponibilidad de hecho pero sin la posibilidad de pretender conducirse como dueño respecto de ella o tenerla por sí con exclusión de cualquier otro.

* Normalmente, la posesión coincide con la propiedad. Como dijo Ihering: la posesión es la exteriorización de la propiedad. Pero a veces la posesión es una apariencia de propiedad: el ladrón de una cosa puede aparecer como dueño, pero sólo tiene la posesión, no la propiedad; el dueño, en cambio, conserva la propiedad —señorío jurídico— aunque ha perdido la posesión —señorío de hecho, concreto, material.

* Quien, como el locatario o depositario, tiene disponibilidad sobre una cosa en base a una relación jurídica personal con su dueño o poseedor, tiene esa cosa a nombre de ese dueño o poseedor y no puede pretender conducirse como dueño: la relación jurídica personal, por el reconocida, lo inhibe. Pero el ladrón no tiene ninguna relación ju-

ridica y puede pretender —toda vez que no reconoce tener la cosa a nombre de otro— manejarse como dueño.

I. La doctrina de la posesión es uno de los más arduos problemas en el Derecho Romano: las denominaciones, los alcances de la protección posesoria, su fundamento, etcétera, han dado lugar a geniales o muy eruditos estudios como los de Donello, Savigny, Saleilles, Ihering, Niebuhr, Bonfante, Riccobono y otros. No resulta, pues, nada fácil compendiar tales temáticas; pero hay que hacerlo, aun con los riesgos de excesivas simplificaciones.

II. Los romanos, a diferencia de la mayoría de otros pueblos, distinguieron tempranamente entre la posesión y la propiedad. Pero, a pesar de concebir a aquélla fundamentalmente como un señorío de hecho o poder de disponibilidad —con prescindencia de su legitimación intrínseca—, le reconocieron u otorgaron distintos efectos jurídicos según distintas circunstancias o requisitos, como el ánimo de conducirse como dueño, la buena fe, la *iusta causa*, el carácter de viciosa o no, el transcurso del tiempo.

Esos efectos jurídicos de la posesión son los siguientes:

(A) Sirve de base a tres modos de adquisición de la propiedad: ocupación, tradición y usucapión.

(B) Fundamenta la legitimación pasiva en un proceso de reivindicación: el poseedor, como demandado, no debe proporcionar ninguna prueba; la otra parte debe probar su derecho de propiedad y si no tiene éxito la cosa sigue en posesión del poseedor.

(C) Cuando hay posesión de buena fe, hay derecho a la adquisición de frutos y se puede reclamar la cosa por la acción Publiciana como si se tratara de una propiedad bonitaria*.

(D) La posesión está protegida contra los actos de perturbación —no contra reivindicaciones— por los interdictos posesorios.

III. Pero su carácter de institución de hecho, fáctica, se pone de relieve si se tiene en cuenta que todos estos efectos jurídicos están necesariamente vinculados con la subsistencia de la posesión: en cuanto ésta cesa, como concreto y actual seño-

SP

104-1

río de hecho, aquellas consecuencias jurídicas, en principio, quedan eliminadas. Así, por ejemplo, no le alcanzan a la posesión los efectos del *postliminium*: a los romanos prisioneros de guerra, cuando volvían a su patria, le eran reintegrados *ipso iure* todos los status y derechos que tenían en el momento de caer prisioneros, pero no continuaban en su anterior condición de poseedores ni de cónyuges, pues posesión y matrimonio eran situaciones de hecho —al margen de teorías o ficciones— y no de derecho.

TERMINOLOGIA

Ella es, a propósito de los poderes de hecho sobre las cosas, muy variada, confusa y cambiante en el tiempo, pero tal vez convenga sintetizarla como se hace a continuación.

POSSESSIO NATURALIS

No es una verdadera posesión, sino la designación del elemento material de la efectiva disposición; es la simple detentación de una cosa, sin el *animus possidendi* (intención de poseer), es decir, sin pretensión de manejarla como dueño. Carece de relevancia jurídica en el sentido de que no otorga protección a su sujeto. Equivale a nuestra tenencia.

POSSESSIO

Así, a secas, o más técnicamente *possessio ad interdicta*, consta, en principio, de dos elementos: el objetivo, que se llamó *corpus*, consistente en la efectiva disponibilidad o señorío de hecho, y el subjetivo, *animus*, (intención) de tenerla por sí y para sí, con exclusión de terceros. Esta posesión es el núcleo esencial de la teoría posesoria y a ella nos referimos de aquí en adelante.

La posesión fue, sin necesidad de otros requisitos —siempre que no fuera viciosa en relación con el perturbador o des-

pojador—, protegida por los interdictos contra actos concretos de perturbación o despojo.

Se distingue la *possessio vitiosa* o *iniusta* de la *iusta*: *vitiosa* o *iniusta* es la que tiene origen violento, clandestino o precario * respecto del anterior poseedor; es decir, que ha habido una toma de posesión por la fuerza, o a escondidas, o por concesión precaria de éste. Esta condición no tiene relevancia con respecto a todos, sino que es sólo relativa al poseedor anterior: contra éste, generalmente, la *possessio vitiosa* no es amparada por interdictos, pero sí contra cualquier otro individuo que intentara turbarla. Así, por ejemplo, el ladrón es *possessor iniustus* —y como tal no tutelado— frente al primitivo poseedor que fue robado, pero es *iustus* y tutelado frente a cualquier tercero.

También se distingue la *possessio bonae fidei* de la *maiae fidei*. Es de buena fe cuando es ejercida con la convicción de no lesionar derechos ajenos —aunque no se tenga *iusta causa*, pues si se la tiene estaríamos ante una *possessio* calificada de *civilis*.

* Ambas *possensiones* —la de buena y mala fe— son tuteladas contra actos perturbadores, pero tienen frente a una reivindicación victoriosa distintas consecuencias: el poseedor de buena fe sólo es responsable por los frutos percibidos desde la *litis contestatio*; el de mala fe, por todos, aun los que no pudieron ser percibidos por su negligencia. Por lo demás, según algunos juristas romanos sostenedores de la idea del título putativo*, la posesión de buena fe, fundada en la convicción de la existencia de una relación jurídica con el precedente poseedor, válida para la transferencia de la propiedad, podía dar lugar a la usucapión.

* Existen los llamados casos anómalos de posesión: se trata de tenencias *alieno nomine* (a nombre de otro), disponibilidades de hecho basadas en una relación jurídica con el dueño o poseedor de la cosa, excluyente, por lo tanto, de cualquier pretensión de *animus possidendi*, pero que, no obstante —y representando un grave escollo para una sistemática fundamentación de la protección interdictal— gozan de los mismos interdictos que las *possensiones*. Son casos anómalos las tenencias del acreedor pignoraticio, del precarista —el que ha recibido el goce de la cosa por parte de un propietario que se reserva el derecho de reclamarla en cualquier momento—, del secuestratario —es decir, aquel que es encargado de guardar un objeto litigioso durante el proceso—, del titular de la enfiteusis* y del de la *superficies**.

POSSESSIO CIVILIS

Es aquella que produce efectos sancionados por el *ius civile*; fundamentalmente, la que tiene los requisitos para la *usucapio* *.

HISTORIA

El modo paulatino en que se destaca la posesión con respecto a la propiedad se evidencia en la evolución sufrida por la *reivindicatio*. En su forma procesal más antigua, la *legis actio sacramento in rem* significaba una contienda en que ambas partes debían probar su mejor derecho a la cosa, y la posesión provisional de ella era confiada a una cualquiera de las partes, sin tener en cuenta quién era poseedor cuando se había entablado el juicio. Pero en sus posteriores versiones, la *per sponsionem* y la *per formulam petitoriam*, sólo el actor debe probar un derecho absoluto; el demandado, poseedor de la cosa, no debe probar nada, y conservará aquélla si el reivindicante no consigue ver reconocido su *dominium*. Queda manifiesta, pues, la relevancia jurídica que adquiere ese efectivo señorío fáctico que es la posesión.

I. Dos instituciones concurren a formar la posesión de los tiempos clásicos: el *usus* y la *possessio*.

II. El *usus* aparece, en los primeros tiempos de Roma, como el ejercicio de hecho de un poder de *mancipium* * no correspondiente, según las *mores maiorum* *, a quien lo ejercita. Dado el carácter genérico del *mancipium* podía resultar, en consecuencia, el *usus* sobre cosas, o sobre servidumbres rústicas, o sobre la mujer incorporada a la familia por matrimonio.

El ejercicio del *usus* —no perturbado ni cuestionado por un eventual verdadero titular del *mancipium*—, por un cierto tiempo —uno y dos años— daba lugar a la adquisición del *mancipium* sobre las cosas, las servidumbres —hasta la *lex Scribonia*—, sobre la mujer —el caso más corriente de adquisición de la *manus* *— y sobre una herencia yacente —con sólo el *usus* sobre algunas de las cosas constituyentes.

III. Al margen del *mancipium* —y, por lo tanto, del *ius quiritium*— se encontraba la *possessio* —vocablo derivado del arcaico *potis* (señor, dominador) y de *sedere* (sentarse, estar establecido)—, señorío permitido por la *civitas* a sus integrantes, *cives*, sobre partes del *ager publicus* —resultante de la expansión hegemónica— que no se hubieran otorgado en propiedad privada, es decir sometido al *mancipium* —posteriormente desglosado en *dominium* *— de los *patresfamilias*.

IV. Ese señorío de los *patres* sobre el *ager publicus* se fue caracterizando como un verdadero derecho de propiedad —la llamada luego propiedad provincial—, pero la posesión como hecho —protegida, tal vez, por medidas de carácter más bien administrativo— evolucionará hasta separarse de aquel señorío y evidenciarse como una institución referible a todas las cosas.

V. El *usus* y la *possessio* tendieron a unirse bajo el común denominador de recaer sólo sobre cosas corporales: las servidumbres dejaron de ser adquiribles por *usucapio*, se desvaneció la adquisición de la *manus* por medio del *usus* no interrumpido por el *trinotium* * y la *usucapio hereditatis* * lo fue de las concretas cosas hereditarias y no ya de la herencia en su universalidad.

VI. Pero con Justiniano, la vieja noción del *usus* como ejercicio de hecho de un poder que se espectraba sobre cosas, personas y derechos, volvió a aflorar en la concepción de la *possessio iuris*.

FUNDAMENTO DE LA PROTECCION POSESORIA

¿Por qué se protegió ese poder fáctico de disposición sobre las cosas en beneficio de quien no es propietario y aun a riesgo de proteger al ladrón? Varias respuestas han querido darse. Las más importantes son las de Savigny y las de Ihering.

Para Savigny el fundamento es la paz pública. Para evitar que los particulares se hagan justicia por sí mismos se otorgan interdictos en favor del mantenimiento del estado posesorio hasta que, eventualmente planteada la controversia de la legitimidad jurídica, el tribunal reconozca al titular no ya de la posesión, sino del *dominium*.

Para Ihering lo que se protege en realidad es la propiedad que normalmente coincide con la posesión. Es verdad que la propiedad se protege por la reivindicación, pero ésta exige la prueba de ese derecho, prueba generalmente difícil. Los interdictos son comodísimos y fácilmente obtenibles por el poseedor, que nada tendrá que probar si contra él se intentase una reivindicación. Los interdictos pueden, es verdad, aprovechar a quien no tiene derecho —incluso a un ladrón—, pero esos casos son los menos frecuentes y pueden remediarse con la interposición de una reivindicación para hacer que la posesión coincida con el derecho de propiedad.

De todos modos, la individuación y tutela de la posesión revela un alto nivel de técnica jurídica alrededor de dos principios básicos: el que un estado de hecho debe presumirse de derecho hasta prueba fehaciente en contrario; el que impide hacerse justicia por sí mismo, aun con convencimiento fundado de tener derecho.

REQUISITOS PARA LA TUTELA POSESORIA

Para la jurisprudencia clásica fueron el *corpus* (cuerpo) o *corpore possidere* (poseer con el cuerpo), es decir, una relación material o física de la persona sobre la cosa; y el *animus possidendi*, es decir, la intención de poseer la cosa para sí, defendiéndola de los intentos de terceros.

Sobre la rigidez o elasticidad con que estos requisitos fueron concebidos se tratará a propósito de la adquisición, conservación y pérdida de la posesión. Aquí corresponde reiterar que la tutela interdictal fue también otorgada a evidentes casos de tenencia a nombre de otro, en los que el título en virtud del cual se tiene la cosa impide la pretensión de poseerla a nombre propio: el del secuestro *, el del precario *, el del *pignus* *, el de la concesión del *ager vectigalis* —variante del *ager publicus* *—, el de la enfiteusis * y el de la *superficies* *.]

Estos casos anómalos —que no tendremos más en cuenta al tratar de las condiciones en que se considera que existe po-

sesión— mostrarían que la jurisprudencia fue auspiciando la protección posesoria no de acuerdo a criterios teóricos a priori, sino pragmáticamente —casos del secuestro, precario y *pignus*— y de acuerdo con las analogías y antecedentes históricos —casos de la enfiteusis y de la *superficies*, influidos por la antigua *possessio* del *ager publicus*.

ADQUISICION DE LA POSESION

Se adquiere *corpore et animo*, es decir, con la aprehensión o entrada en el poder de disposición de la cosa y la intención de poseerla a título exclusivo.

I. En cuanto al *corpus*, la concesión materialista inicial se elasticizó hasta no hacer necesario el directo o inmediato contacto con la cosa: hubo, por ejemplo, adquisición del animal salvaje desde que cayó en la red, y ya se han visto aquellos casos de tradición * en que no había una efectiva entrega de la cosa sino una simbólica o puramente mental puesta a disposición.

II. Una parecida atenuación se produjo con respecto al *animus*. El *sui iuris infans* —al igual que los dementes— no podía en la época clásica tener *animus*, pero Justiniano admitió que pudiera entrar personalmente en posesión con sólo la *auctoritas* de su tutor.

También en el derecho clásico, sólo se podía adquirir la posesión por intermedio de otros cuando éstos estaban sometidos al *paterfamilias*: *filiifamilias*, esclavos, mujeres *in manu*. Pero Justiniano consideró que se podía adquirir por intermedio de personas extrañas aun no teniendo conciencia de ello o no teniendo posibilidad de voluntad —dementes, infantes y personas jurídicas—: sólo era necesaria una posterior ratificación a lo actuado por el tutor, curador o procurador, respectivamente.

CONSERVACION DE LA POSESION

También el principio por el cual estaba condicionada a la coexistencia del *corpus* y el *animus* sufrió excepciones y atenuaciones.

I. Así, se seguía conservando *nudo animo* (con la sola voluntad) la posesión de fundos destinados al pastoreo alternado durante el año, cuando éstos eran abandonados por los pastores. Se mantenía la posesión sobre el esclavo en fuga y se adquirían las cosas por él adquiridas.

En el derecho justinianeo, los casos, antes excepcionales, de *possessio animo detentata* (posesión mantenida sólo por la voluntad) se hicieron regla con la sola exigencia de la existencia del *corpus* al comienzo de la posesión.

II. Aun respecto a la subsistencia del *animus* hay un criterio elástico: así, por ejemplo, se considera que la posesión se mantiene durante la sobreviniente enfermedad mental del poseedor.

PERDIDA DE LA POSESION

Aparte de los casos voluntarios de pérdida de posesión —como el abandono o la tradición— y de la pérdida del *corpus* —cuando ha huido el esclavo, o se ha perdido definitivamente la cosa, o cuando ha sido robada, o incorporada a otra cosa—, conviene destacar que se perdía la posesión por la muerte del poseedor, en el sentido de que no era transmisible a los herederos. En razón de deficiente capacidad intelectual no podía ser perdida *animo* (por voluntad) la posesión por el demente ni por el *infans*, salvo, en este último caso, con la interposición de la *auctoritas* * del tutor.

DEFENSA DE LA POSESION

Se efectúa por los llamados interdictos posesorios. Recuerdese que los interdictos * eran órdenes del magistrado —expedidas a pedido de parte— a una persona determinada para que restituyera o exhibiera algo o se abstuviera de un proceder. Eran producidos sin verificación previa de los hechos invocados por el peticionante. De allí que fueran órdenes condicionales para el destinatario: si la condición respondía a la realidad, la orden debía ser obedecida; si no, el destinatario podía ignorarla.

- * A título de ejemplo se da el texto del interdicto *de vi*: "Por cuanto en este año tú lo arrojaste por la fuerza, o tu servidumbre lo hizo, supuesto que él poseyera, en lo que a ti respecta, sin violencia, ni clandestinidad, ni precariamente, restitúyelo allí con cuantas cosas allí él tenía en ese momento". Como se observa, la orden debía ser cumplida sólo si se daban estas dos condiciones: 1) que lo hubiera arrojado por la fuerza en el año precedente al interdicto; 2) que la posesión no hubiera sido viciosa * respecto del destinatario del interdicto.
- * En cualquier caso, si no era cumplida la orden, podía abrirse una instancia procesal para saber si esa condición se verificaba en el caso: en ese supuesto el destinatario sería condenado al pago de daños e intereses.

Los interdictos posesorios eran de dos clases: 1) los de retener la posesión (*retinendae possessionis*), orientados hacia el mantenimiento de la posesión, es decir, a defender el estado posesorio actual o inmediato anterior frente a perturbaciones o agresiones, y 2) los de recuperar la posesión (*recuperandae possessionis*), dirigidos a reparar el despojo de la posesión, es decir, a restablecer la posesión perdida por manejos de otros.

Recuérdese que, en principio, en el derecho clásico la posesión no era protegida si era viciosa * respecto al perturbante o despojador.

INTERDICTOS PARA RETENER LA POSESION

(A) *Uti possidetis* (como poseéis), que protegía al actual poseedor de un inmueble.

(B) *Utrubi* (en cual de las dos partes), que protegía la posesión del que había poseído la cosa mueble durante la mayor parte del año anterior a la emisión del interdicto.

- * En el derecho justinianeo se asimiló el interdicto *utrubi* al *uti possidetis*, quedando protegido por una acción única el poseedor actual.

INTERDICTOS PARA RECUPERAR LA POSESION

(A) *De vi* (por la fuerza), que obligaba, en los términos consignados un poco más arriba, al que se había apoderado por la fuerza de un fundo o edificio, a restituirlo al poseedor despojado.

61 504 1

(B) *De vi armata* (por violencia a mano armada), que obligaba a restituir el inmueble arrebatado a mano armada, aun cuando la posesión interrumpida hubiera sido viciosa y aun transcurrido cualquier intervalo temporal.

- En el derecho justiniano se funden estos dos interdictos en uno que presenta el término anual del interdicto *de vi* y que, como el interdicto *de vi armata*, no tiene en cuenta el carácter vicioso de la posesión.

COPOSESION

Así como no era concebible que una cosa estuviera en el *dominium* de varias personas, en el sentido de que cada una de éstas tuviera pleno señorío sobre aquélla, tampoco se concebía la posesión integral de una cosa por varias personas. Pero, al igual que en el caso del condominio, se admitió que varias personas pudieran poseer la misma cosa por determinadas partes indivisas: cada una de aquéllas tenía la posesión no de una parte material determinada, sino de una determinada parte ideal o intelectual.

QUASI POSSESSIO

En el proceso de extensión de la tutela interdictal se había llegado a proteger al titular de una *superficies** con un específico interdicto *de superficiebus* análogo al genérico *uti possidetis*. De allí se pasó a conceder una tutela especialísima al que, de entre varios pretendientes del goce de un usufructo, lo detentase materialmente. Obsérvese que en este caso no se trata de un señorío fáctico sobre la cosa sino de un ejercicio fáctico de un derecho.

La extensión de esa protección a otras hipótesis de ejercicio de derechos de servidumbres llevó a los juristas —a Gayo, por ejemplo— a hablar de *quasi possessio* para destacar la analogía entre esos casos de ejercicio fáctico de derechos y los casos de posesión sobre cosas.

En la época de Justiniano, de la idea de una analogía se

pasó a una identificación: había *possessio* de cosas corporales —la clásica posesión— y *possessio* de cosas incorpóreas o *iura** (derechos). La *quasi possessio*, en su nueva concepción de *possessio iuris* (posesión de un derecho), se extendió a todos los casos en que se ejercitaba de hecho un derecho. Y se llegó hasta concebir la *possessio status* (posesión de estado) como la condición de quien goza en apariencia de un cierto status personal —*libertatis, civitatis, familiae*— independientemente de ser realmente titular de ese status.

LAS SERVIDUMBRES

Ya se ha visto que en el Derecho Romano se configuraron algunos derechos sobre las cosas, tutelados *erga omnes*, que, al coexistir con la propiedad, la comprimen toda vez que le desgajan específicos contenidos, pero que, cuando cesan, la propiedad elásticamente recupera aquellos contenidos.

Son derechos limitados sobre cosa ajena: si la cosa deviniera propia del titular de cualquiera de esos derechos, ese derecho se extinguiría, confundido en la absolutez del derecho de propiedad.

Esos derechos sobre cosa ajena (*iura in re aliena*) se dividen en (A) servidumbres y (B) derechos reales pretorianos.

CONCEPTO DE SERVIDUMBRE

Para el derecho clásico, servidumbre era la sujeción jurídica permanente de un fundo para proporcionar determinado beneficio a otro fundo ajeno, constituida de una vez por los respectivos propietarios.

En el derecho justiniano, la categoría de servidumbre se alarga con la inclusión de las equivocadamente designadas *servidumbres legales* —que son, en realidad, límites legales del dominio— y de los antiguos derechos de usufructo, uso, habitación y *operae servorum*.

Estos últimos son involucrados en la categoría de las que